EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - HOSPITAIS, ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS ("CNSaúde"), entidade sindical inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.496.574/0001-34, com sede no Setor de Rádio e TV Sul 701, Conjunto E, Edifício Palácio do Rádio I, Bloco 03, nº 130, 5º andar, Asa Sul, Brasília/DF, por seus advogados subscritos **(doc. 01)**, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 102, I, *a* e *p* e no art. 103, IX, da Constituição Federal, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Com pedido de concessão de medida cautelar

a fim de que seja conferida interpretação conforme à Constituição ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92; e ao art. 57 da Lei nº 8.981/95 **(doc. 02)**, de modo a se excluir do âmbito desses dispositivos a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC que corrige o levantamento de depósitos judiciais. As razões que conduzem à procedência do pedido serão desenvolvidas adiante, conforme o roteiro abaixo.

I. PRELIMINARMENTE: O CONHECIMENTO DA PRESENTE ADI

I.1. Legitimidade ativa, abrangência nacional e pertinência temática

I.2. Cabimento e objeto

II. O MÉRITO

II.1. Síntese da controvérsia jurídica: a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e de CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais tributários

II.2. A Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais não configura renda, lucro ou qualquer tipo de acréscimo patrimonial (art. 146, III, *a*; art. 153, III; e 195, I, *c*; da Constituição Federal)

II.3. As razões de decidir do Tema 962 e a sua necessária aplicação aos depósitos judiciais: os efeitos transcendentes das decisões em repercussão geral e a necessidade de uniformização da matéria em prol da segurança jurídica (art. 102, §3º; art. 5º, *caput*, da Constituição Federal)

II.4. A afronta à isonomia (art. 5º, caput, e art. 150, II, da Constituição Federal)

II.5. A afronta à legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal)

II.6. A afronta à capacidade contributiva e ao não confisco (art. 145, §1º; art. 150, IV, da Constituição Federal)

II.7. Subsidiariamente: a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a parcela de correção monetária que compõe a Selic

III. OS PEDIDOS

III.1. Pedido cautelar

III.2. Requerimentos, pedidos principais e pedidos subsidiários

I. PRELIMINARMENTE: O CONHECIMENTO DA PRESENTE ADI

I.1. Legitimidade ativa, abrangência nacional e pertinência temática

1. Em relação à sua ***legitimidade ativa***, a Requerente, fundada em 22 de março de 1994, é entidade sindical de terceiro grau – o mais elevado existente na legislação sindical – que representa todos os estabelecimentos de serviços de saúde do País, congregando quase uma dezena de Federações e uma centena de Sindicatos[1].

2. A CNSaúde tem por objetivo primordial coordenar e zelar pelos direitos e interesses das entidades econômicas do setor de serviços de saúde junto aos órgãos públicos e, inclusive, defender os interesses coletivos ou individuais de suas associadas perante o Poder Judiciário (cf. art. 3º de seu Estatuto Social[2]).

3. O art. 2º do Estatuto Social[3] da Requerente indica seu *status* de **representante nacional dos direitos e interesses das entidades que reúnem as categorias econômicas da área da saúde** para os fins do art. 8º, III, da Constituição Federal[4]. Assim, ela se enquadra inequivocamente como legitimada ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, na condição de confederação sindical, conforme previsto no art. 103, IX, da Constituição Federal e no art. 2º, IX da Lei 9.868/1999.

4. Desde a sua fundação em 1994, a legitimidade ativa da Requerente tem sido reconhecida por essa Eg. Corte em diversas oportunidades[5], inclusive na defesa de interesses

---

[1] Informações disponíveis em: http://cnsaude.org.br/sobre-a-cnsaude/

[2] "Art. 3º - São prerrogativas da CNS:
I – representar, defender e amparar perante os poderes públicos e entidades privadas os interesses individuais e coletivos da categoria econômica da saúde, bem como coordenar a atuação de suas entidades filiadas, representando-as, defendo-as e amparando-as tanto no âmbito judicial, como no extrajudicial, sempre que assim designada; (...)".

[3] "Art. 2º - São objetivos da CNS a coordenação e a defesa das entidades representativas das categorias econômicas da área da saúde, assim como a adoção e o pleito de interesse das filiadas.".

[4] "Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (...).".

[5] Por exemplo: ADI 1589 (Rel. Min. Eros Grau), ADI 1692 (Rel. Min. Ilmar Galvão), ADI 1931 (Rel. Min. Marco Aurélio), ADI 4350 (Rel. Min. Luiz Fux), ADI 4468 (Rel. Min. Celso de Mello), ADI 5336 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), ADI 5344 (Rel. Min. Edson Fachin), ADI 5504 (Rel. Min. Dias Toffoli), ADI 5544 (Rel. Min. Luiz Fux), ADI 5605 (Rel. Min. Edson Fachin), ADI 6149 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), ADI 6317 (Rel. Min. Edson Fachin), ADI

de suas filiadas em matéria tributária, dentre as quais citamos as ADIs 1802[6], 2028[7], 2228[8] e 2621[9], que impugnaram leis federais que criaram requisitos para fruição de imunidades.

5. Mais recentemente, na ADPF 499, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, a Requerente questionou a Lei Complementar nº 116/2003, que estabelece regras gerais sobre o Imposto sobre Serviços (ISS), e leis de diversos Municípios que, após alterações implementadas pela Lei Complementar nº 157/2016, instituíram modificações substanciais acerca do local onde seria considerada a ocorrência do fato gerador do referido imposto. Na ocasião, o Exmo. Relator ratificou a legitimidade ativa da CNSaúde, tendo sido acompanhado, à unanimidade, nesse ponto. Veja-se:

> **"A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNS), autora da ADPF 499, representa em caráter nacional empresas de prestação de serviços de saúde, entre as quais figuram as operadoras de planos de saúde e odontológicos, afetadas diretamente pela legislação questionada** (art. 3º, XXIII, da LC 116/2003, quanto aos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa). Não bastasse, sua legitimidade para deflagrar o controle concentrado já fora aferida em outras oportunidades perante essa CORTE (ADI 4.350, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2014; ADI 1.802, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2018; ADI 4.468, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)." (Negritos acrescidos)[10].

6. Em relação à ***abrangência nacional***, como adiantado, a Requerente congrega atualmente 8 (oito) federações, em diferentes estados do País, e aproximadamente 90 (noventa) sindicatos, que representam diversas atividades no âmbito da saúde, entre hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas e patologia clínica, serviços de diagnóstico, imagem e fisioterapia, e outros estabelecimentos do gênero. Trata-se de um setor que reúne mais de **250 mil estabelecimentos** (sendo 4.198 hospitais, pelos últimos dados), gerando mais de 2,5 milhões de empregos (números de 2018)[11].

6362 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), ADI 7222 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), ADPF 151 (Red. Min. Gilmar Mendes), ADPF 227 (Rel. Min. Rosa Weber), ADPF 229 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e ADPF 325 (Rel. Min. Rosa Weber).

[6] Quanto à legitimidade temática da Requerente, o Min. Dias Toffoli assim se manifestou:
"Não merece, contudo, prosperar a preliminar ventilada, eis que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade ativa da autora para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, conforme se depreende dos julgamentos da ADI 1.589/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/3/05, e da ADPF 151/DF-MC, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/5/11." (ADI 1802, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 03.05.2018).

[7] Rel. Min. Rosa Weber, DJe 08.05.2017.

[8] Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.05.2017.

[9] Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.06.2017.

[10] Trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes na ADPF 499 (fl. 27): STF, Tribunal Pleno, ADPF 499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.07.2023.

[11] Informações retiradas de: http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2018/09/CNSaude_Agenda_Saude_2019_Aprova%C3%A7%C3%A3o-compressed.pdf

7. Restando inconteste a legitimidade ativa e a abrangência nacional da Requerente, inegável é também a ***pertinência temática*** em relação à controvérsia jurídica constitucional que será aprofundada: o reconhecimento da (in)constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais tributários.

8. Os filiados da Requerente – que atuam em parceria com o Poder Público, suprindo, muitas vezes, demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) - têm interesses específicos e diretos no julgamento da presente demanda, na medida em que os depósitos judiciais são a forma mais célere de suspensão da exigibilidade de créditos tributários objeto de autuações, execuções fiscais e discussões judiciais no geral, conforme previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional[12].

9. Diversos entes públicos exigem, para contratar ou realizar pagamentos de serviços prestados pelas instituições privadas de saúde, a regularidade fiscal dessas pessoas jurídicas, comprovada por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND), emitida quando não há créditos tributários exigíveis pelo Fisco, ou por meio da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CEPEN), gerada quando há créditos com exigibilidade suspensa[13].

10. Sendo a realização de depósitos o meio mais gravoso de garantia do crédito tributário, mas também o mais célere - pois, a partir da disponibilização dos valores integrais

---

[12] "Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral; (...).".

[13] A interpretação é extraída por alguns entes de:
Constituição Federal,
"Art. 195 ...
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória nº 526, de 2011) (Vide Lei nº 12.453, de 2011) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)";

Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)
"Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:
(...)
III - serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;"

Por exemplo, o Estado do Paraná: https://site.mppr.mp.br/saude/Noticia/E-legitima-exigencia-de-provas-de-regularidade-fiscal-de-entidade-privada-de-saude#:~:text=%C3%89%20leg%C3%ADtima%20a%20exig%C3%AAncia%20de%20provas%20de,o%20repasse%20de%20verbas%20%C3%A0%20entidade%20privada ; o Município de São Paulo: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/parecer-procuradoria-geral-do-municipio-pgm-819-de-30-de-junho-de-2015

dos tributos à conta corrente vinculada ao Juízo, há um dever do magistrado de reconhecer a suspensão do crédito, conferindo o direito à fruição dos seus consectários legais - diversas empresas e entidades do setor, sem alternativa, optam pela sua efetuação[14].

11. Em que pese esses depósitos judiciais serem muitas vezes imprescindíveis para a manutenção do funcionamento e dos recebimentos do SUS, o levantamento dos depósitos judiciais, ao fim dos processos, tem sua atualização – pela Selic[15] - tributada pela União, por IRPJ e por CSLL, uma vez que o ente entende que a incidência da Selic configura acréscimo patrimonial. Esse entendimento equipara os depósitos judiciais (um gravoso e necessário meio para suspensão da exigibilidade de créditos tributários) a investimentos financeiros, em que há ganho de capital a ser tributado.

12. Ocorre que, conforme será abordado no capítulo II.4, o levantamento de depósitos judiciais e a sua correção pela Selic não podem ser comparados a investimentos que visam ao lucro e ao acréscimo patrimonial. Um dos principais motivos que tornam essa equiparação inconstitucional é o fato de que o levantamento de depósitos judiciais tributários ocorre apenas quando o sujeito passivo da relação tributária ganha a causa. Em outras palavras, o levantamento dos depósitos se dá quando, em decisão transitada em julgado, o Judiciário conclui que o ente tributante agiu afrontando a Constituição Federal ou a lei.

13. Essa inconstitucionalidade ou ilegalidade cometida pelo ente é o fundamento para que seja reconhecido o direito de o contribuinte levantar os valores depositados que, se efetuados com base na Lei nº 9.703/98, são corrigidos, em nível federal, pela Selic ou índice que a ela não seja superior, caso estados e municípios elejam correção diversa[16]. Não há, portanto, **nenhuma semelhança entre os depósitos judiciais e um investimento livremente escolhido pelo contribuinte com o intuito de incrementar o seu patrimônio**.

[14] Em pesquisa realizada com auxílio do *software* da Inspira, uma *legaltech* líder no mercado jurídico e muito utilizada para pesquisas jurisprudenciais, com indicação dos termos de busca "Tema 504", número do Repetitivo do STJ que veiculava a controvérsia, e as palavras "Hospital", "Clínica", "Casa de Saúde", "Laboratório", "plano de saúde", "seguro saúde", foram localizados mais de 127 decisões sobre o assunto, nos TRFs 1, 2, 3, 4 e 5.
[15] Para depósitos efetuados até 15.09.2024, conforme art. 37, II, da Lei nº 14.973/2024.
[16] Conforme decidido por esta Corte quando do julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1.062 da RG): "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.". (Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, DJe 26.09.2019).

14. Considerando também a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige os depósitos judiciais, nota-se que os estabelecimentos de saúde são grandes contribuintes dos referidos tributos – circunstância que não cessará se equalizada a inconstitucionalidade objeto desta ação.

15. Afinal, os gastos com o consumo de bens e serviços de saúde representam cerca de 9,6% do PIB brasileiro[17]. Em termos de arrecadação, estudo realizado pela Requerente, em 2018, aponta que a arrecadação tributária total (federal, estadual e municipal) do setor foi de R$80,8 bilhões de reais. Apenas a título de IRPJ e CSLL, o setor arrecadou R$11,1 bilhões de reais e, no período de 2013 a 2017, esse montante chegou a R$50,9 bilhões[18].

16. Nesse contexto, a incidência do IRPJ e da CSLL também sobre a Selic em levantamento de depósitos judiciais, à revelia de sua real base de cálculo, atinge e onera direta e excessivamente grande parte das pessoas jurídicas do setor de saúde, **integrando os fatores para o cálculo dos preços por elas praticados, o que estende os efeitos do ônus econômico suportado, indiretamente, às pessoas físicas tomadoras de seus serviços**.

17. Importa pontuar referida abrangência na perspectiva de se destacar que essa Eg. Corte também já reconheceu a legitimidade ativa de confederações sindicais setoriais em diversos processos objetivos tributários[19] cujos interesses defendidos ultrapassavam a esfera subjetiva dos representados pela confederação. Conforme decisão unânime na ADI

---

[17] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33482-conta-satelite-de-saude-9-6-do-pib-foram-gastos-no-consumo-de-bens-e-servicos-de-saude-em-2019

[18] Informações retiradas de: http://fbh.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Livro-tributacao.pdf.

[19] Foi, por exemplo, reconhecida a legitimidade ativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação Nacional do Comércio (CNC) nas seguintes ações abstratas tributárias:

- ADI 5635 (CNI): em face da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 7.428/2016, que instituiu condição para concessão e manutenção de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros relacionados ao ICMS;
- ADI 5051 (CNC): em face do art. 1º da Lei Complementar nº110/2001, de 29 de junho de 2001, que criou o adicional de 10% à multa sobre o FGTS para o caso de demissão sem justa causa;
- ADI 4905 (CNI): em face dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação introduzida pela Lei n.º 12.249, de 11 de junho de 2010, e, por arrastamento, os artigos 36, caput e 45, § 1.º, inciso I da Instrução Normativa RFB n.º 1.300, de 20 de novembro de 201. "(...) esse conjunto de regras concebeu um complexo de normas punitivas, que estabelecem, ao contribuinte que age de boa-fé, multa de 50% do valor total do crédito objeto de declaração de compensação não homologada ou do valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.";
- ADI 4612 (CNC): em face dos seguintes dispositivos, da expressão "plena ou não" do artigo 2º, da Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de 1988 e de dispositivos do artigo 4º, da Lei nº 15.242/2010, especificados no pedido, ambas do Estado de Santa Catarina, que tratam de IPVA.

4364, de relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, tal circunstância não interfere no reconhecimento da pertinência temática do caso. Veja-se:

> "A meu ver, a exigência de pertinência temática não impede, **quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários**, o amplo conhecimento da ação, nem a declaração de inconstitucionalidade da norma, para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente.
>
> Foi o que ocorreu, mais recentemente, na ADI nº 15/DF, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 31/09/07, em que a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.689, que mantinha em vigor a contribuição para o FINSOCIAL. A decisão beneficiou todos os potenciais contribuintes do tributo e não apenas a classe representada pela entidade requerente (Confederação das Associações de Microempresas do Brasil), até porque, segundo entendimento da Corte, inconstitucional era a manutenção do FINSOCIAL para quaisquer contribuintes, não havendo especificidade relativa às microempresas. A inconstitucionalidade era, portanto, essencialmente a mesma para todos."[20] (Negritos do original).

18. É incontroverso, portanto, o interesse específico e direto da Requerente e de suas associadas em obter o provimento jurisdicional desta Eg. Corte no sentido de que seja declarada inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais, sendo clara a sua legitimidade ativa que também se vincula "*ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação.*"[21].

I.2. **Cabimento e objeto**

19. Conforme art. 102, I, *a*, da Constituição Federal, a ação direta de inconstitucionalidade é cabível como meio de impugnação de lei ou ato normativo federal ou estadual. Na presente, questiona-se a interpretação conferida pela União e seus órgãos aos seguintes dispositivos de leis federais, transcritos em atendimento ao art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99:

> ***a)*** **Art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966):**
>
> "Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

[20] STF, Tribunal Pleno, ADI 4364, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 16.05.2011.
[21] STF, Tribunal Pleno, ADI 1.507 MC AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 6.06.1997.

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.";

b) **Art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977:**

"Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.";

c) **Art. 3º, §1º da Lei nº 7.713/1988**:

"Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.";

d) **Art. 8º, da Lei nº 8.541/1992:**

"Art. 8° Serão consideradas como redução indevida do lucro real, de conformidade com as disposições contidas no art. 6°, §5°, alínea b, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, as importâncias contabilizadas como custo ou despesa, relativas a tributos ou contribuições, sua respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros encargos, cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial em garantia."; e

e) **Art. 57, caput, da Lei nº 8.981/1995:**

"Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto

no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.".

20. Não se questiona, portanto, na presente ação, o art. 37, II, da Lei nº 14.973/2024, que determina que, a partir de 16.09.2024, os depósitos judiciais tributários deverão ser submetidos apenas à *"correção monetária por índice oficial que reflita a inflação"*. Questiona-se tão somente a constitucionalidade da interpretação atualmente conferida pela União **aos dispositivos acima transcritos**, a fim de exigir IRPJ e CSLL sobre a Selic que, com base na Lei nº 9.703/1998, ainda corrige os depósitos judiciais feitos até a entrada em vigor da Lei nº 14.973/2024[22].

21. Objetiva-se, portanto, na presente ação, que seja conferida, aos referidos dispositivos de leis federais, interpretação conforme à Constituição, notadamente aos seus artigos 145, §2º; 153, III; 195, I, *c*; 150, II; e 150, I, a fim de excluir, do âmbito de incidência do IRPJ e da CSLL, a Selic que corrige os depósitos judiciais tributários, uma vez que é inegável que tal exação afronta a capacidade contributiva, o conceito constitucional de renda e lucro, os princípios da isonomia e a legalidade tributária.

22. Destaca-se que a controvérsia não é nova no âmbito dessa Eg. Corte. Em 2021, sob relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, o Tribunal Pleno analisou dois Temas de repercussão geral relacionados ao presente: o RE 855.091 (Tema 808) e o RE 1.063.187 (Tema 962).

23. No primeiro – Tema 808 -, mediante a técnica da interpretação conforme à Constituição, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da incidência de imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações advindas de exercício de empregos, cargos ou funções.

24. No segundo precedente vinculante – Tema 962 -, esse Eg. STF analisou situação equivalente à presente, concluindo pela inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL

[22] A vigência da Lei nº 9.703/1998 para depósitos judiciais tributários feitos até a entrada em vigor da Lei nº 14.973/2024 é reconhecida pelo próprio art. 40, parágrafo único, da Lei nº 14.973/2024:
"Art. 40. (...)
Parágrafo único. Os valores que estejam depositados na Conta Única do Tesouro Nacional serão corrigidos conforme previsto na norma vigente ao tempo do depósito, aplicando-se o disposto neste Capítulo a partir de sua vigência.".

sobre a Selic que corrige a repetição de indébito tributário, a partir de interpretação conforme à Constituição dos **mesmos artigos de leis federais acima elencados e que são objeto da presente ação direta**, conforme se verifica a partir do dispositivo decisório daquele v. acórdão:

> "Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, nos termos do voto do Relator.".

25. Ocorre que, em que pese a semelhança entre as situações da repetição de indébito e dos depósitos judiciais, o Tema de Repercussão Geral em questão se voltou à análise específica da primeira hipótese, em razão da delimitação de seu objeto – ainda que, de sua *ratio decidendi*, possa se permitir a mesmíssima conclusão de inconstitucionalidade que ora se suscita.

26. Em dezembro/2022, esse Eg. Tribunal chegou até a realizar primeira análise sobre o tema, mas, ao fazê-lo, no ARE 1.405.416 (Tema 1243 da RG[23]), acabou por entender ser *"(...) infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais"*.

27. Desse modo, considerando o óbice processual criado, a partir do julgamento do Tema 1243, para a admissibilidade de recursos extraordinários que objetivam o controle concreto de constitucionalidade dos referidos dispositivos legais, **não restou alternativa** senão a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que, em controle abstrato e objetivo, com efeitos vinculantes e eficácia *erga omnes*, essa Eg. Corte defina se a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais está amparada pelas referidas regras e princípios constitucionais – ou, diversamente, como se defende nesta, há inconstitucionalidade parcial dos dispositivos.

28. Para os fins do art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99, sistematizamos os fundamentos jurídicos para as impugnações dos referidos dispositivos de leis federais:

[23] STF, Tribunal Pleno, ARE 1.405.416, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Dje 03.03.2023.

(i) A Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais não configura renda, lucro ou qualquer tipo de acréscimo patrimonial, (art. 146, III, *a*; art. 153, III; e 195, I, *c* da Constituição Federal);

(ii) As razões de decidir do Tema 962/STF e a sua necessária aplicação aos depósitos judiciais: a necessidade de respeito à segurança jurídica e os efeitos transcendentes das decisões em repercussão geral (art. 102, §3º; art. 5º, *caput*, da Constituição Federal);

(iii) A afronta à isonomia (art. 5º, caput, e art. 150, II, ambos da Constituição Federal);

(iv) A afronta à legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal); e

(v) A afronta à capacidade contributiva e ao não confisco (art. 145, §1º, e art. 150, IV, ambos da Constituição Federal).

29. As referidas afrontas à Constituição Federal serão detidamente comprovadas no decorrer da presente petição, sendo robustecidas por Pareceres Acadêmicos de autoria do Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Ayres Barreto, (**doc. 03**) e pelo Professor de Direito Constitucional e Ministro aposentado dessa Eg. Corte, Carlos Ayres Britto **(doc. 04),** produzidos quando do julgamento do tema pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça.

30. Inegável, portanto, o cabimento da presente ADI e, como se demonstrará detidamente adiante, a procedência do pleito nesta veiculado.

II. O MÉRITO

II.1. Síntese da controvérsia jurídica: a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e de CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais tributários

31. A presente ação direta visa à declaração de inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais

tributários, nos termos das razões de decidir do RE 855.091 (Tema 808 da RG) e, principalmente, do RE 1.063.187 (Tema 962 da RG), ambas de relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, cujas teses firmadas foram, respectivamente, as seguintes:

> "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função." (Tema 808 da RG)"; e
>
> "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário." (Tema 962 da RG).

32. O julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962 da RG) significou verdadeira alteração da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2013, no REsp 1.138.695 (Temas Repetitivos 504 e 505)[24], sob a relatoria do Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, ocasião na qual aquele Eg. Tribunal havia entendido pela legalidade de incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige as repetições de indébito e o levantamento dos depósitos judiciais tributários, conforme teses abaixo transcritas:

> **Tema Repetitivo 504**: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.".
>
> **Tema Repetitivo 505**: "Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa.".

33. Considerando a superação de sua jurisprudência pelo RE 1.063.187 (Tema 962 da RG), a Primeira Seção do Eg. STJ reanalisou, em abril/2023, as teses fixadas nos Temas Repetitivos 504 e 505, conforme determina o art. 1.040, II, do CPC/2015[25]. O v. acórdão de readequação foi assim ementado:

> "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO RE N. 1.063.187 - SC (TEMA N. 962 - RG). INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 505/STJ PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE IR E CSLL SOBRE A TAXA SELIC QUANDO APLICADA À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO DA TESE REFERENTE

[24] Primeira Seção, DJe 31.05.2013.
[25] "Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (...)."

AO TEMA 504/STJ E DEMAIS TESES JÁ APROVADAS NO TEMA 878/STJ. RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(...).

2. Em julgado proferido no RE n. 1.063.187/SC (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27.09.2021) o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 962 da repercussão geral, em caso concreto onde apreciados valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 3º, §1º, da Lei n. 7.713/88; ao art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e ao art. 43, II e §1º, do CTN para excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Fixou-se então a seguinte tese: Tema nº 962 da Repercussão Geral: 'É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário'.

3. Em sede de embargos de declaração (Edcl no RE n. 1.063.187/SC, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02.05.2022) o STF acolheu pedido de modulação de efeitos estabelecendo que a tese aprovada no Tema n. 962 da repercussão geral produz efeitos ex nunc a partir de 30.9.2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17.9.2021 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30.9.2021 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.

4. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no Tema n. 962 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, restam preservadas as teses referentes ao TEMA 878/STJ e exsurgem as seguintes teses, no que concerne ao objeto deste repetitivo:

| TEMA 504/STJ: '***Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL***'; e

| TEMA 505/STJ: 'Os ***juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário*** se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC'.

5. Em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso especial da FAZENDA NACIONAL e o acolho em nova e reduzida extensão apenas para modificar a redação da tese referente ao TEMA 505/STJ, mantendo a tese referente ao TEMA 504/STJ.". (Grifos do original).

34. Conforme se verifica, em que pese a equivalência jurídica entre a repetição de indébito e o levantamento de depósitos judiciais, **a Primeira Seção do Eg. STJ readequou**, com base no Tema 962 da RG, **apenas a tese referente à repetição de indébito**,

em verdadeira redução teleológica das razões de decidir produzidas por essa Eg. Corte em sede de repercussão geral, pautando-se no fato de que a situação fática que ensejou a afetação do Tema nessa Eg. Corte Constitucional era relativa à repetição de indébito apenas.

35. A necessidade de padronização do entendimento quanto à tributação da Selic foi devidamente apontada em embargos de declaração perante aquele Eg. Tribunal. No entanto os embargos restaram desprovidos em fevereiro deste ano[26], consolidando referida interpretação restritiva do entendimento desse Eg. STF – o que suscitou a necessidade de se propor a presente ação em sede de controle abstrato e com objeto especificamente voltado aos depósitos.

36. Como pretendemos demonstrar, a **Selic** incidente sobre a repetição de indébito e sobre o levantamento dos depósitos judiciais **é a mesma** e há **equivalência jurídica entre a repetição de indébito e o levantamento de depósito judicial** para fins de aplicação das razões de decidir firmadas no Tema 962. Assim, respeitosamente, a manutenção da cobrança de IRPJ e de CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais tributários, perpetrada pela União com chancela do Eg. STJ, afronta, de uma só vez: a capacidade contributiva e os conceitos de renda e lucro; os efeitos vinculantes das razões de decidir dos precedentes firmados em recurso extraordinário com repercussão geral e a segurança jurídica; a isonomia; e a legalidade tributária, pelas mesmas razões constitucionais observadas no julgamento do mencionado Tema de Repercussão Geral.

II.2. A Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais não configura renda, lucro ou qualquer tipo de acréscimo patrimonial

37. O artigo 153, III, da Constituição Federal, outorga à União a competência para instituir imposto sobre a *renda e proventos de qualquer natureza*. Em linha com a regra de competência delineada no artigo 146, III, *a*, da Constituição Federal, o Código Tributário Nacional (CTN) apresenta, em seu art. 43, o fato gerador do imposto de renda:

> "Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

[26] Primeira Seção, Embargos de declaração no REsp 1.138.695, DJe 25.02.2025.

> I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
>
> II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.".

38. A incidência do imposto, portanto, depende da aquisição de disponibilidade sobre um conjunto de bens, valores ou direitos dos quais o contribuinte possa dispor e que integram seu patrimônio, representando um *(i) saldo positivo resultante do (ii) confronto entre (ii.a) certas entradas e (ii.b) certas saídas, ocorridas ao longo de um dado (iii) período*[27].

39. A atribuição para a criação da CSLL, por sua vez, foi conferida à União por meio do artigo 195, I, *c*, da Constituição Federal, segundo o qual o ente poderá instituir contribuição social a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, incidente sobre o **lucro.**

40. Lucro, em apertada síntese, representa ganho auferido durante uma operação comercial ou por meio do exercício de uma atividade econômica. Com reservas às diferenças entre a teoria contábil e o direito tributário, lucro é o resultado positivo da diferença entre o total das receitas percebidas e as despesas incorridas pela pessoa jurídica considerada.

41. Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL decorrem, portanto, de idêntica materialidade, uma vez que pressupõem a aquisição de disponibilidade de *acréscimo patrimonial*, tal como corrobora o artigo 57 da Lei nº 8.981/1995, segundo o qual se aplicam à CSLL (Lei nº 7.689, de 1988) *as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas***.**

42. Em linha com o princípio da capacidade contributiva, há muito esse Eg. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, *por mais variado que seja o conceito de renda, todos os economistas, financistas e juristas se unem em um ponto:* ***renda é sempre um ganho ou acréscimo de patrimônio***[28].

43. Nesse contexto, à luz dos conceitos constitucionais de renda e lucro, são precisas as considerações de Luís Eduardo Schoueri:

---

[27] GONÇALVES. José Artur Lima. *Imposto Sobre a Renda – Pressupostos Constitucionais*. São Paulo: Malheiros Editores, 1ª Edição, 2ª Tiragem, pág. 179.
[28] STF. Recurso Extraordinário nº 89.791. Relator Ministro Cunha Peixoto. Julgamento em 03.10.1978.

> "Na linha do raciocínio desenvolvido pela **teoria da renda produto** (ou teoria da fonte), **tem-se por renda o fruto periódico de uma fonte permanente.** Em imagem figurativa, diz-se que a renda seria o fruto que se obtém, sem que pereça a árvore de onde ele provém. A 'árvore' seria o capital e o 'fruto', sua renda. Só caberia falar em renda no momento em que o fruto se destaca da árvore (realização).
>
> Já na **teoria da renda-acréscimo patrimonial**, o conceito de renda surge a partir da comparação da situação patrimonial em dois momentos distintos. **Pressupõe a teoria, assim, um intervalo consistindo a renda na diferença positiva entre a situação patrimonial no final e no começo do período.**"[29] (Negritos acrescidos).

44. A distinção conceitual entre *renda* e *proventos de qualquer natureza*, contudo, não permite concluir que qualquer elemento positivo corresponda a *acréscimo patrimonial* e, via de consequência, se qualifique como fato gerador do IRPJ. Segundo Ricardo Mariz de Oliveira, "*As causas de produção de acréscimo patrimonial, passíveis de se submeter ao imposto de renda, são causas internas ao patrimônio, geradas e manejadas por ele ou por seu titular, distintas de causas exclusivamente externas a esse mesmo patrimônio*"[30].

45. Nessa linha, é inconstitucional a tributação de valor que não represente acréscimo patrimonial efetivo, eis que deixaria de incidir sobre a renda do contribuinte para recair sobre o seu patrimônio.

46. Desbordando das balizas impostas pela Constituição Federal e pelo CTN para a incidência do IRPJ e da CSLL, a interpretação conferida pela União aos artigos 3º, §1º, da Lei nº 7.713/1988 e art. 17, do Decreto-lei nº 1.598/1977, inclui, entre as grandezas a serem computadas na base de cálculo dos referidos tributos, valores que **não** representam ganho ou acréscimo patrimonial, quais sejam, os juros indenizatórios e a correção monetária, pois equiparam o levantamento de depósitos judiciais a situações diametralmente opostas, como o resgate de títulos ou debêntures. Confira-se:

> **Decreto-lei nº 1.598/77:**
> "Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem."

---

[29] SCHOUERI, Luís Eduardo. *O conceito de renda e o art. 43 do CTN:* entre disponibilidade e econômica e disponibilidade jurídica. In: André Elali, Evandro Zaranza e Kallina Flôr dos Santos (coords.), Direito corporativo. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 343/344.
[30] OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. *Fundamentos do Imposto sobre a Renda.* São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 287.

> **Lei nº 7.713/1988:**
> "Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.
> § 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.".

47. A interpretação conferida aos dispositivos transcritos afronta os artigos 153, III; e 195, I, *c*, da Constituição Federal, submetendo à tributação pelo IRPJ e pela CSLL valores incompatíveis com as hipóteses constitucionais de incidência.

48. Esse entendimento também foi ratificado pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, ao proferir seu voto no RE nº 1.063.187/SC, no sentido de que *os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor*.

49. Assim, embora definidos em lei, os fatos geradores não podem extrapolar os limites da competência tributária definida pela Constituição Federal e por ela delegada ao legislador complementar, conforme previsto no art. 146, III, *a*. Essa é a orientação do Eg. STF, representada pelo irretocável voto do Exmo. Min. Luiz Galloti no julgamento do RE nº 71.758:

> "Sr. Presidente, é certo que podemos interpretar a lei, de modo a arredar a inconstitucionalidade. Mas, interpretar interpretando e, não, mudando-lhe o texto, e, menos ainda, criando um novo imposto, que a lei não criou.
>
> Como sustentei muitas vezes, ainda no Rio, se lei pudesse chamar de compra o que não é compra, de importação o que não é importação, de exportação o que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o sistema constitucional tributário inscrito na Constituição."[31].

50. Nessa linha, e conforme já destacado, os depósitos judiciais tributários são a forma mais célere (ainda que ao mesmo tempo mais gravosa) de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), consubstanciando, para o credor, a mais segura garantia de pagamento dos tributos discutidos judicialmente. Em outras palavras, decorrem de uma **situação de necessidade** de um contribuinte que, ao fim, se afere o direito à liberação do depósito, comprovou ter contra si uma **exação indevida**.

[31] RE nº 71.758-GB, Relator Min. Thompson Flores, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/1972, DJ 31.08.1973.

51. É dizer, portanto, que os depósitos judiciais tributários não se assemelham em nada a um investimento facultado ao contribuinte, mas se constituem como verdadeiro ônus em face de uma cobrança que, ao fim, se demonstrará indevida.

52. Quando devolvidos em favor dos contribuintes – o que só ocorre após decisão transitada em julgado que reconheça a inconstitucionalidade ou a ilegalidade cometida pelo ente tributante -, os depósitos são atualizados pelos mais diversos índices, de acordo com a legislação do ente federativo, desde que não ultrapassem o índice estabelecido pela União (ARE 1.216.078, Tema 1062 da RG).

53. Para a **União**, em relação aos depósitos judiciais tributários feitos até setembro/2024, a atualização se dá pela **Selic** (Lei nº 9.703/1998), índice que possui caráter híbrido, comportando, a um só tempo, **correção monetária e juros indenizatórios**.

54. Para melhor alcance da sua função de índice de **correção monetária**, tem-se como necessária a análise do conceito de *inflação*.

55. A melhor doutrina econômica define inflação como fenômeno correspondente ao aumento generalizado e persistente dos preços de produtos e serviços em determinado mercado. Como esclarece Alexandre Schwartsman[32], economista e ex-diretor do Banco Central do Brasil, essas *"duas características são cruciais, pois se apenas poucos preços aumentam (...) não há como caracterizar um processo inflacionário, ainda que o índice de preços mostre valores positivos. Da mesma forma, se há um aumento de todos os preços num dado mês, (...) mas estabilidade em seguida, também não temos como caracterizar inflação."*.

56. A inflação deteriora o poder de compra, tendo em vista que, se constantes as demais grandezas (como o produto do capital – rendimentos - e do trabalho - salário), o aumento persistente e generalizado dos preços implicará queda real de consumo.

57. Para atenuar os efeitos do fenômeno inflacionário, a correção monetária é instrumento voltado à preservação do poder aquisitivo no tempo, recompondo os valores corroídos pela inflação, em linha com o princípio da propriedade estampado no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. Esse foi o entendimento consolidado pelo Plenário da Eg. Suprema Corte no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da RG):

[32] Disponível em: http://g1.globo.com/economia/inflacao-o-que-e/platb, acessado em 31.03.2025.

> "(...) 3. **A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação.** É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. **A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal** (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. **A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.** 5. Recurso extraordinário parcialmente provido."[33].

58. Tratando-se de mero reajuste do valor monetário, portanto, a correção **não se adequa ao conceito de rendimento**, como leciona Bulhões Pedreira[34], pois

> "A lei fiscal não contém dispositivo geral regulando a determinação do juro no curso da inflação, que autorize distinguir entre reposição do capital e juro. Diversas disposições especiais, todavia, autorizam a correção monetária do principal de empréstimos e declaram que as variações nominais resultantes dêsse reajustamento monetário não constituem rendimento.".

59. O mesmo entendimento é pacífico no âmbito dessa Eg. Corte e foi destacado no julgamento de mérito do Tema 962 da RG, notadamente no voto do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, que consignou que *"a correção monetária embutida na taxa SELIC não se qualifica como um ganho novo, mas sim a recomposição de uma perda."*.

60. E tal compreensão sequer é inovadora, o que se exemplifica pelo fato de que já era destacada pelo Exmo. Ministro Luiz Fux ainda quando Ministro do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que *"a correção monetária não traduz acréscimo patrimonial, pois sua aplicação não gera qualquer incremento no capital, mas tão somente o restaura dos efeitos corrosivos da inflação, razão pela qual não há como fazer incidir Imposto de Renda, sob pena de tributar-se o próprio capital."* [35].

61. Assim, é indubitável que a parcela da Selic que corresponde à correção monetária visa a tão somente manter os valores reais dos depósitos judiciais tributários para que – caso eles venham a ser levantados pelos contribuintes – não tenham sofrido perdas

[33]STF, Tribunal Pleno, RE 870.947, Relator Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017.
[34] PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de Renda. Rio de Janeiro: APEC Editora, 1969, Capítulo 8, item 8.20 (30).
[35] REsp 544.009, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.02.2004, p. 220.

inflacionárias, evitando que ocorra a indevida diminuição do seu patrimônio e o enriquecimento sem causa da União.

62. Por sua vez, quanto à sua parcela de **juros indenizatórios**, o papel da Selic está definido nos artigos 394, 395 e 404 do Código Civil[36], nos termos dos quais a ausência de pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer constitui o devedor em mora e assegura ao credor o pagamento das perdas e danos com atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

63. Os juros de natureza moratória, portanto, são devidos em razão do inadimplemento e visam indenizar o credor, como leciona Sílvio de Salvo Venosa[37]:

> "Se houve inadimplemento, parcial ou total, surge o dever de indenizar. Indenizar é reparar o dano, o prejuízo. *Indene* é aquele que não sofreu prejuízo, que está incólume. Indenizar é tornar indene. Tanto na responsabilidade contratual, como na extracontratual, **para que surja o direito à indenização, há necessidade de um *prejuízo*, isto é, um dano avaliável, uma perda, uma diminuição no patrimônio.**" (Negritos acrescidos).

64. Esse é, inclusive, o entendimento manifestado por essa Eg. Corte no mencionado RE 855.091 (Tema 808 da RG), como se verifica do excerto abaixo:

> Não parece haver dúvidas, portanto, de que a expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a **indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro**. Para o legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele. Note-se que o legislador previu a possibilidade de serem as perdas efetivas maiores que os juros de mora, e por isso, possibilitou, caso não haja pena convencional, a concessão de indenização complementar.
>
> Cumpre destacar, ainda, que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso. **Vide**, em primeiro lugar, que eles não constituem frutos civis (parcela acessória que, em regra, segue a sorte do principal) decorrentes da exploração econômica do capital, como ocorre, por exemplo, com os juros remuneratórios (ou compensatórios) em relação ao mútuo feneratício. ***É necessário notar, ainda, que a causa que gera o direito aos juros de mora legais decorre de um ato ilícito imputado ao devedor consistente no não***

[36] Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.
[37] VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos* (vol. 2). São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012, p. 323.

> ***pagamento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor.***[38]***.***

65. Assim, é inequívoca a natureza indenizatória dos juros moratórios, os quais visam à recomposição do prejuízo causado ao credor, diante do período em que seu patrimônio, indisponível, sofre afetação pela inflação.

66. Em seu já mencionado parecer, o eminente Professor Ayres Britto concluiu igualmente pela natureza indenizatória da Selic que corrige os depósitos judiciais tributários, uma vez que:

> ***(i)*** A mera atualização monetária e a percepção de juros de mora não se caracterizam como renda ou lucro; e
>
> ***(ii)*** A Selic incidente sobre depósitos **não** possui natureza jurídica de lucros cessantes.

67. Em relação ao item *(i)*, o Professor ratifica que, ao afirmar que a Selic que recai sobre os depósitos judiciais atua de forma simultânea como **índice de correção monetária** e **taxa de juros moratórios** (art. 2º-A, § 2º, da Lei nº 9.703/1998 com o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995), reveste-se da mesma natureza dos juros que incidem sobre os precatórios, conforme art. 100, §12, da Constituição Federal:

> "Art. 100. (...)
>
> §12 A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo **índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança**, e, **para fins de compensação da mora**, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, **ficando excluída a incidência de juros compensatórios**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).". (Negritos acrescidos).

68. Sobre a **diferença entre juros moratórios e juros compensatórios**, manifestou-se o Ilmo. Parecerista:

> "Enquanto os juros remuneratórios ou compensatórios têm, como regra, origem numa postulação negocial, econômica e obviamente lícita da parte que os titulariza (o que não se altera mesmo que sejam quantificados em lei), **os juros moratórios ressaem de um fato ilícito que acomete o seu titular**. Um fato, portanto, que passa ao largo da vontade ou mesmo da iniciativa substantivamente livre do destinatário dos juros de mora. **Não por acaso, então, que o referido §12 do art. 100 da Constituição**

[38] Trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no v. acórdão do RE 855.091 (Tema 808), pg. 15. Itálico e negrito do trecho final incluídos.

> **correlaciona juros de mora e precatórios judiciais, mas destes afasta a incidência de juros compensatórios, considerando-se que os precatórios nada mais são do que a dimensão financeira quantificada de uma obrigação estatal de pagar**. O que, obviamente, decorre da **necessidade jurídica de o Poder Público reparar um dano que tenha indisputavelmente causado a um particular**. Aliás, no art. 404, o Código Civil expressamente estabelece a imbricação conceitual e também funcional entre juros de mora e reparação de danos ou prejuízo (...).".

69. Já no tocante à impossibilidade de enquadrar a Selic como renda ou lucro, o Professor Ayres Britto concluiu em seu parecer que:

> "Vê-se, pois, que os juros de mora têm natureza essencialmente reparatória, servindo para *cobrir* um prejuízo, na linguagem até figurativa de que se vale o parágrafo único do art. 404 do Código Civil. Noutras palavras, os juros de mora servem de *antídoto* para uma causa exógena e anterior de minoração patrimonial. O que, antecipo, já seria o suficiente para afastar, em linha de princípio, os juros moratórios da incidência do IRPJ e da CSLL, centrados que são, esses tributos, na materialização de um acréscimo, de um *plus* de substância jurídico-econômica, e não de um mero fenômeno de reparação patrimonial.".

70. O Exmo. Ministro aposentado desse Eg. STF explicou que os juros moratórios referentes à Selic não se confundem com lucros cessantes em razão de não ser possível "*correlacioná-los a essa ou aquela aplicação econômica assim produtiva como esperada*" e acrescentou que a indenização por lucros cessantes "*pressupõe a perda de uma chance indubitável de ampliar o patrimônio mediante aplicação produtiva dos recursos tredestinados ao depósito judicial*". Sobre as possibilidades de aplicação dos depósitos judiciais, que afastam a natureza de lucros cessantes da Selic, o Professor afirma que:

> "Não se pode aprioristicamente vinculá-lo [o depósito] a um tipo específico de emprego produtivo, pois são inimagináveis as possibilidades de uso do valor – com destaque, no mais das vezes, para o próprio custeio das empresas, o que evidentemente não corresponde a lucro. Mas o certo é que se pode, e assim juridicamente se determina, presumir que a parte preterida da disponibilidade do dinheiro sofreu um decréscimo patrimonial, a ser justamente recomposto pela incidência dos juros moratórios. (...).
> Os juros de mora correspondem, então, a uma técnica normativa de neutralização dos danos emergentes absoluta e presuntivamente sofridos por quem se vê privado do uso de um valor patrimonial.".

71. O Parecerista também ressaltou a impossibilidade de se identificar como renda ou lucro a Selic, devido à sua função de recomposição de perda inflacionária, bem como reiterou a responsabilidade do Estado por ter dado azo ao depósito posteriormente levantado:

> "Como o instituto jurídico da taxa SELIC não incide senão para recompor o nível patrimonial desfalcado pela realização do depósito judicial, inválida é sua identificação com renda, ou lucro, ou provento. Óbvio! E se digo óbvio, é porque, como se sabe, há uma relação de referibilidade entre inflação, período de indisponibilidade do dinheiro e taxa SELIC. Esta não existiria sem aquelas, assim como o ondear das plantas não existiria sem o vento e a temperatura a impactá-las. E o certo é que o fato em si da inflação e da privação financeira imposta aos contribuintes também tem a ver com a eficiência do Estado para lidar com ela. Eficiência que é um dos expressos deveres constitucionais da Administração Pública de qualquer das unidades federadas do Brasil (cabeça do art. 37 da Constituição Federal, já transcrito), a inadmitir que ela, Administração Pública brasileira, venha a fazer de um processo inflacionário que não soube combater, ou, pior ainda, que eventualmente passou a deflagrar, um dado gerador e até mesmo incrementador de receitas tributárias. O mesmo ocorrendo com o tempo de indisponibilidade financeira provocado pela ilicitude da exação levada a efeito pela Administração Fazendária.
> Seria a configuração da esdrúxula interpretação jurídica de que o Tesouro Estatal bem pode tirar partido da inflação em si, pois, afinal, taxa SELIC e inflação se imbricam conceitualmente.".

72. Pela natureza inequívoca de danos emergentes é que não devem incidir o IRPJ e a CSLL sobre a Selic que recai sobre o levantamento dos depósitos judiciais tributários, sendo a atual cobrança formalmente inconstitucional, por contrariar o art. 146, III, *a*, da Constituição Federal, bem como materialmente inválida, por ir contra os conceitos de renda e lucro dos artigos 153, III e 195, I, *c*, da Constituição Federal.

73. A chancela conferida pelo E. STJ (*d.m.v.*, de forma equivocada) à tributação da Selic incidente sobre os depósitos judiciais tributários se deu, justamente, em razão das diferenças com relação ao já explicado cenário em que a controvérsia se insere e à natureza dos juros incidentes sobre tais depósitos, que, no entender daquele Eg. Tribunal, é de mero dano remoto ou indireto (lucro cessante), classificado pelo Exmo. Min. Mauro Campbell Marques como "*aquele dano decorrente dos compromissos feitos pelo credor em seu próprio prejuízo durante a mora do devedor e que não estavam no contrato e não eram previsíveis pelo devedor*". A própria classificação, como se vê, denota uma divergência em relação à real situação dos depósitos judiciais tributários, que decorrem de relação de direito público e acabam por ter caráter compulsório.

74. Tal natureza, contudo, como se extrai do próprio voto do Exmo. Min. Dias Toffoli no Tema 962, não poderia ser presumida, notadamente diante das diversas realidades de pessoas jurídicas existentes – o que pode ser evidenciado a partir do próprio universo de representadas da Requerente, cujo setor engloba empresas dos mais diversos portes e entidades sem fins lucrativos. Afinal, como evidenciado no voto do referido Relator:

> "*[...]* para ser aceita a ideia de que os juros de mora legais revestem-se, de modo estrito, da natureza de lucros cessantes, seria necessário pressupor, por exemplo, que o credor normalmente aplicaria, durante todo o período em atraso, a integralidade das verbas não recebidas tempestivamente em algum instrumento que lhe gerasse renda na mesma porcentagem da taxa Selic.
> Considerando as inúmeras realidades das pessoas jurídicas existentes, as quais podem se afigurar não só como sociedades empresárias comuns, mas também como fundações, associações sem fins lucrativos, sociedades simples, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas individuais de responsabilidade limitada etc., não me parece razoável pressupor tal entendimento."

75. Conforme será aprofundado a seguir, não há como fugir, no caso dos depósitos judiciais tributários, das conclusões esboçadas – que se coadunam com a exata conclusão a que chegou esta Eg. Corte no julgamento o RE 1.063.187 (Tema 962 da RG) –, sendo integralmente aplicáveis as suas razões de decidir ao presente caso.

II.3. As razões de decidir do Tema 962 e a sua necessária aplicação aos depósitos judiciais: os efeitos transcendentes das decisões em repercussão geral e a necessidade de uniformização da matéria em prol da segurança jurídica

76. Em julgamento finalizado em 27.09.2021, o Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, com base no art. 153, III, e art. 195, I, *c*, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: *"é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário"*. Trata-se do já mencionado RE 1.063.187 - Tema 962 da sistemática da repercussão geral, julgado sob relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli.

77. Apesar de a tese ser bastante sucinta e refletir exatamente a conclusão dos julgadores, é importante destacar que o elemento vinculante do precedente, como se sabe, são as razões de decidir (ou fundamentos determinantes) dos votos da maioria. Essa conclusão é extraída do próprio texto constitucional, que após a Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a prever *"a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso"* (art. 102, §3º, da Constituição Federal), o que, atualmente, opera como sistemática de admissibilidade e como técnica de julgamento de recursos extraordinários.

78. O Código de Processo Civil de 2015, ao versar sobre o tema, adotou previsão análoga à da Lei nº 11.418/2006, ao estabelecer que *"para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico,*

político, social ou jurídico que ***ultrapassem os interesses subjetivos do processo****"* (art. 1.035, §1º). Não por outro motivo, o CPC/2015 elencou entre os precedentes de observância obrigatória as decisões proferidas em recurso extraordinário analisado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 927, III).

79. No mesmo sentido decidiu essa Eg. Corte no RE 955.227 (Tema 885 da RG)[39], de relatoria do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, ao reconhecer expressamente que as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral passariam a produzir os mesmos efeitos vinculantes *erga omnes* das decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se a tese de julgamento firmada pela Eg. Corte na ocasião:

> "1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.
>
> 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.".

80. Ao se equipararem os efeitos das decisões proferidas em controle abstrato e em recurso extraordinário com repercussão geral para os fins da interrupção dos efeitos futuros das coisas julgadas individuais, este Tribunal, sem sombra de dúvidas, aproximou definitivamente ambos os controles de constitucionalidade. Tal ponto resta ainda mais claro nos seguintes trechos do v. acórdão do RE 955.227 (Tema 885 da RG):

> "Como ressaltei, com a sistemática da repercussão geral, instituída pela EC nº 45/2004, e a sucessiva adoção de teses de julgamento, o processo de objetivação do controle difuso se tornou ainda mais claro. O Código de Processo Civil de 1973, alterado pela Lei nº 11.418/2006, ao regulamentar o instituto, definiu como requisito para o reconhecimento da repercussão geral 'a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa' e do mesmo modo dispõe o CPC/2015, em seu artigo 1.035, §1º.
>
> 18. Nessa linha, ressalto que o art. 927, III, do novo código processual, afirma que 'os juízes e tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos', deixando expresso que o Poder Judiciário está também vinculado às decisões desta Corte proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral. (...).
>
> 21. Assim, aproveito para afirmar ser necessário que esta Corte reconheça que a declaração de inconstitucionalidade, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, possui os mesmos efeitos vinculantes e eficácia erga omnes

[39] STF, Tribunal Pleno, RE 955.227, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02.05.2023.

> atribuídos às ações de controle abstrato. Nesses casos, a resolução do Senado, a que faz menção o art. 52, X, da CF/1988, possuirá a finalidade de publicizar as decisões de inconstitucionalidade, não configurando requisito para a atribuição de efeitos vinculantes *erga omnes*.". (Trecho do voto do Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
>
> "Sugere [o relator], ainda, que, nesses casos, a resolução do Senado (art. 52, X, da CF/1988), deva ter a finalidade de publicizar as decisões de inconstitucionalidade, não configurando requisito para a atribuição de efeitos vinculantes erga omnes.
>
> Penso que essa solução é a que mais se compatibiliza com o postulado da segurança jurídica, uma vez que a Constituição Federal e a legislação processual estabelecem que, para o reconhecimento da repercussão geral, a controvérsia, além de ser dotada de relevância econômico, político, social ou jurídico, deve ultrapassar os interesses subjetivos da causa. Em especial, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 admite reclamação para a garantia da observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
>
> Assim, vê-se que, de fato, houve a objetivação do controle difuso quando proferido em sede de repercussão geral." (Trecho do voto do Min. Alexandre de Moraes).
>
> "Ante a decisão da Corte na Rcl nº 4.335/AC, adoto o posicionamento doutrinário de Teori Zavascki, para quem a decisão em que o Supremo Tribunal Federal declara, em sede de controle difuso de constitucionalidade não submetido à sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade de lei só adquire eficácia **erga omnes** (**não havendo, obviamente, súmula vinculante com mesmo teor**) com a resolução do Senado Federal. Ficam, assim, preservados os poucos efeitos práticos que ainda subsistem na aplicação do art. 52, X, da Constituição Federal.". (Trecho do voto do Min. Dias Toffoli, negritos do original).
>
> "27. Enfim, com relação às decisões plenárias realizadas sob o rito da repercussão geral, apesar de exigir maior esforço interpretativo, decorreu do Código de Processo Civil de 1973, a partir da Lei nº 11.418, de 2006**, e atualmente resulta do CPC de 2015 a imputação do caráter vinculante e da eficácia contra todos às decisões tomadas pelo Tribunal Pleno desta Corte em sede de repercussão geral**.". (Trecho do voto do Min. André Mendonça, negritos do original).

81. Sendo, portanto, idênticos os efeitos desses tipos de controle de constitucionalidade, as decisões em sede de repercussão geral passam a estar dotadas de efeitos vinculantes, que são assim definidos pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes:

> "Em verdade, o efeito vinculante decorre do particular papel político-institucional desempenhado pela Corte ou pelo Tribunal Constitucional, que deve zelar pela observância estrita da Constituição nos processos especiais concebidos para solver determinadas e específicas controvérsias constitucionais. (...).
>
> Vale ressaltar que o alcance do efeito vinculante das decisões não pode estar limitado à sua parte dispositiva, devendo considerar, também, os chamados 'fundamentos determinantes'. (...)."[40].

[40] STF, Tribunal Pleno, Reclamação nº 1987, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.05.2004.

82. E esse é também o entendimento doutrinário do Ministro, inspirado pelos efeitos do controle de constitucionalidade alemão:

> "Tal como assente em estudo que produzimos sobre este assunto, que foi incorporado às justificações apresentadas no aludido Projeto, a eficácia *erga omnes* e o efeito vinculante deveriam ser tratados como institutos afins, mas distintos. Vale transcrever, a propósito, a seguinte passagem da justificação desenvolvida:
>
> '[...]. Trata-se de instituto jurídico desenvolvido no Direito processual alemão, que tem por objetivo outorgar maior eficácia às decisões proferidas por aquela Corte Constitucional, assegurando força vinculante não apenas à parte dispositiva da decisão, mas também aos chamados **fundamentos** ou **motivos determinantes** (*tragende Gründe*).'"[41]. (Grifos do original).

> "(...) Se o tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei do Estado A, o efeito vinculante terá o condão de impedir a aplicação de norma de conteúdo semelhante do Estado B ou C, que explica o efeito vinculante, suas consequências e a diferença entre eles e a eficácia, seja inter partes ou *erga omnes*.
> Estas propostas não só reforçam o papel do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Carta Magna, mas também contribuem para a celeridade e economia processuais na medida em que, com a decisão de um determinado caso e mediante a aplicação da eficácia 'erga omnes' e do efeito vinculante, propiciam solverem-se todas as questões semelhantes ou idênticas."[42].

83. Principalmente a partir do CPC/2015, a vinculação pelos fundamentos determinantes restou inequivocamente aplicável não apenas em sede de controle de constitucionalidade, mas como decorrência lógica da adoção de um sistema de precedentes. Essa conclusão resta incontroversa a partir da leitura do art. 489, §1º, V:

> "Art. 489.
> (...)
> § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
> (...)
> V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (...).".

84. No mesmo sentido, manifestou-se o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso em obra dedicada ao tema do controle de constitucionalidade no Brasil:

> "Em sucessivas decisões, o Supremo Tribunal Federal estendeu os limites objetivos e subjetivos das decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade, com base em uma construção que vem denominando transcendência dos motivos determinantes. Por essa linha de entendimento, é reconhecida eficácia vinculante não apenas à parte dispositiva do julgado, mas também aos próprios fundamentos que embasaram a decisão. Em outras palavras:

---

[41] MENDES, Gilmar. *O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nos processos de controle abstrato de normas.*, Revista Jurídica Virtual Brasília, vol. 1, n. 4, agosto 1999, p 1.
[42] MARTINS, Ives Gandra. MENDES, Gilmar Ferreira. *Controle concentrado de constitucionalidade*: comentários à Lei nº 9.868, de 10-11-1999. 3 ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009, p. 397-398.

> juízes e tribunais devem acatamento não apenas à conclusão do acórdão, mas igualmente às razões de decidir.
> (...)
> Os efeitos transcendentes integram a lógica da jurisdição constitucional. Os tribunais devem observar as teses firmadas pelo STF. (...).”[43].

85. Desse modo, é possível estabelecer três premissas, derivadas dos efeitos vinculantes adotados pela jurisprudência desta Eg. Corte, bem como a partir da leitura dos referidos dispositivos constitucionais e do CPC/2015 e das conclusões doutrinárias:

(i) o elemento vinculante de um acórdão não é apenas o seu dispositivo, mas as suas razões de decidir;

(ii) a tese de julgamento deve apenas indicar as razões de decidir do julgado e, quando não o faz, é imprescindível que se retorne ao acórdão, a fim de extrair os seus fundamentos determinantes;

(iii) até mesmo essa Eg. Corte deve manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsto no art. 926, do CPC.

86. Especificamente quanto ao item (iii) supra, o dever estabelecido pelo art. 926 do CPC/2015 concretiza a proteção da segurança jurídica — expressamente prevista no art. 5º, *caput*, da Constituição Federal — no processo de formação e aplicação de precedentes pelos próprios Tribunais.

> “O art. 926, CPC, institui claramente o que a doutrina chama de *stare decisis* horizontal. Ao dizer expressamente que há dever de outorgar unidade ao direito e de fazê-lo seguro - o que implica torná-lo cognoscível, estável e confiável – o legislador obviamente determinou ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça respeito aos próprios precedentes, além de ter determinado aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça respeito à própria jurisprudência formada a partir dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Isso porque a primeira condição para que exista um sistema de precedentes *e* de compatibilização vertical das decisões judiciais é o respeito por parte das Cortes Supremas aos seus próprios precedentes.”[44].

[43] BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 7 ed, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 248-9.
[44] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de processo civil comentado. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1006.

87. Trata-se, como se vê, da dimensão horizontal dos precedentes ou autoprecedentes, que gera aos Tribunais um dever de consideração de seus próprios paradigmas em nome da isonomia, da segurança e da previsibilidade jurídica:

> "Entendemos que o ideal de coerência e previsibilidade dos atos emanados do Estado é um dos fundamentos das democracias, na medida em que indivíduos ou pessoas jurídicas em situações análogas não podem ser discriminadas e têm o direito de pautar suas ações futuras em expectativas de que terão o mesmo tratamento recebido em situações passadas. [...], citando Frederick Schauer, a vida em sociedade é moldada por experiências passadas e por expectativas criadas para o futuro.
>
> [...]. O mandamento de proteção e respeito a esses direitos deve também ser considerado quando da análise das próprias decisões entre si; do sistema que elas geram; dos efeitos que elas causam na vida das pessoas; e da expectativa que criam.
>
> Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Professor e, então advogado, Luís Roberto Barroso:
>
> > 'A obrigação dos órgãos do Poder Público de não vulnerar a confiança legítima e de agir com boa-fé é inerente ao Estado democrático de direito. Sob um regime constitucional, Estado e sociedade não podem ser vistos como antagonistas ou como pólos opostos de uma relação conflituosa. Ao contrário, ambos devem conviver em unidade e harmonia, compartilhando valores, princípios e objetivos comuns. Nesse ambiente, a relação entre o Estado e o particular não opõe duas partes privadas, cada qual defendendo seu interesse, embora também entre partes privadas haja o dever recíproco de boa-fé. Na verdade, o Poder Público deriva sua autoridade do conjunto de administrados, agindo em nome e por conta da totalidade da população, não se concebendo que possa agir deslealmente em relação a seus próprios constituintes.
> > A proteção da confiança ou das expectativas legítimas, assim como a boa-fé, são princípios que se dirigem, primariamente, à Administração Pública e ao Poder Judiciário. Compete a tais órgãos aplicarem o direito aos casos concretos e, nesse ofício, devem atuar com certa constância e previsibilidade, já que lhes cabe preservar a ordem jurídica existente e assegurar a isonomia perante a lei. [...].'[45]"[46].

88. Desse modo, é inegável que o julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962) gerou expectativa legítima de que as situações análogas seriam tuteladas pelas mesmas normas jurídicas (razões de decidir) criadas por esta E. Corte. Sendo o levantamento de depósitos judiciais equiparável, por diversos prismas (com destaque para os expostos no item II.4 a seguir), à repetição de indébito, conferir tratamento tributário distinto à Selic que atualiza um ou outro fere a racionalidade e a segurança que se espera do sistema de precedentes.

---

[45] BARROSO, Luís Roberto. Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Revista de direito do Estado: RDE, n. 2, p. 261-288, abr./jun. 2006, p. 277-278.

[46] PENCAK, Nina Pinheiro. *Direito tributário e controle de constitucionalidade:* o STF como intérprete da Constituição tributária à luz do sistema de precedentes. 2025. 491f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025, p. 203-204.

89. Após breve digressão sobre a vinculação em nosso sistema de precedentes, verifica-se a necessidade de extrair, do RE 1.063.187, os seus fundamentos determinantes, a fim de demonstrar, portanto, que eles são igualmente aplicáveis para a declaração de inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL tanto sobre a SELIC na repetição de indébito quanto no levantamento de depósitos judiciais. É o que passaremos a expor.

a. As razões de decidir do RE 1.063.187 (Tema 962 da RG)

90. Conforme já mencionado, em 27.09.2021 o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal apreciou, sob relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, o RE 1.063.187 - Tema 962 da repercussão geral - e reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário. O paradigma derivou de acórdão de Tribunal Regional Federal que reconheceu, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN – **objeto desta ADI** - de forma a afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.

91. Ao se debruçar sobre referida declaração incidental de inconstitucionalidade em razão de recurso da União, o Plenário desse E. STF chancelou o controle de constitucionalidade dos diversos dispositivos que impõem a tributação da Selic, chegando aos seguintes termos:

> "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, nos termos do voto do Relator.".

92. A fim de que restem claras as razões que embasaram os votos que formam o v. acórdão do RE 1.063.187 (Tema 962 da RG), bem como dos embargos de declaração opostos pela União, passe-se à análise das manifestações dos Ministros que apresentaram voto escrito em ambos os julgamentos virtuais (Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso), a iniciar pelo voto do Exmo. Relator no julgamento de mérito encerrado em 27.09.2021.

93. No voto proferido pelo **Exmo. Ministro Dias Toffoli**, verificamos os seguintes fundamentos:

- No julgamento do RE 855.091 (Tema 808 da RG), o Eg. STF firmou a tese de que "*não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função*". Apesar de ser distinto, o caso possui similaridades com a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic aplicável à repetição de indébito;

- O direito aos juros de mora legais decorre de um ato ilícito imputado ao devedor consistente no não pagamento dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor nas datas estabelecidas;

- A legislação civil vai no sentido de que as perdas e os danos pagos ao lesado em razão do inadimplemento de uma obrigação de pagar em dinheiro de natureza indenizatória ou não, devem ser os mais amplos possíveis, insuscetível de diminuição patrimonial pela incidência do imposto de renda sobre o valor dos juros de mora;

- O legislador tributário já reconheceu que os juros de mora consistem em indenização (Lei nº 4.506/64, art. 16, p. único);

- O imposto de renda pode alcançar os valores relativos a lucros cessantes, mas não os relativos a danos emergentes;

- Os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor;

- Cuidando-se da obrigação de pagar em dinheiro, é preferível dizer que o atraso em seu adimplemento gera danos emergentes;

- Para ser aceita a ideia de que os juros de mora legais se revestem, de modo estrito, da natureza de lucros cessantes, seria necessário pressupor, por exemplo, que o credor normalmente aplicaria, durante todo o período em atraso, a integralidade das verbas não recebidas tempestivamente em algum instrumento que lhe gerasse renda na mesma porcentagem da taxa Selic;

- Os juros de mora legais têm natureza autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso. Logo, o tributo restituído e o montante correspondente à taxa Selic possuem naturezas distintas, de modo que o acessório não segue a sorte do principal;

- Como foi decidido por esta Eg. Corte no Tema 808, mesmo que se considere que os juros de mora legais envolvidos pela taxa Selic devida no contexto em tela abranjam não só danos emergentes, mas também lucros cessantes, não vislumbro a possibilidade de submetê-los à tributação pelo imposto de renda e pela CSLL, sem se ferir o conteúdo mínimo das materialidades previstas no art. 153, III, e no art. 195, I, c, da Constituição.

94. Ainda quanto ao mérito, o **Exmo. Ministro Gilmar Mendes** seguiu as razões de decidir do relator, ressalvando, em atenção ao dever de coerência, seu entendimento pessoal em relação ao tema:

> "(...) nada obstante a minha compreensão pessoal já enunciada quando do julgamento do RE nº 855.091/RS, representativo do Tema nº 808 da repercussão geral, não deixo de perceber que o eminente relator destes autos, Ministro Dias Toffoli, reproduziu com fidedignidade a ratio decidendi do colegiado enunciada naquela ocasião e que hora se replica.".

95. O **Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso**, por sua vez, enquanto terceiro Ministro a apresentar voto escrito no julgamento do RE 1.063.187, apoiou a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicável à repetição de indébito sobre os seguintes fundamentos:

- A União efetua a devolução de seus indébitos tributários aplicando a taxa SELIC, a título de juros de mora. Estes constituem verbas de natureza indenizatória devidas em decorrência de perdas e danos advindos de ato ilícito, conforme previsto no art. 395, do Código Civil;
- Os juros de mora quando visam recompor danos emergentes objetivam a compensação de uma perda efetivamente sofrida e, por isso, não sofrem incidência tributária, já que não há uma riqueza nova no patrimônio do contribuinte;
- Quando os juros adquirem a natureza de lucros cessantes, o objetivo é de que atuem para garantir um "ganho esperável", o qual se traduz em nova manifestação de riqueza e, por isso, devem ser tributados pelo imposto de renda;
- Os juros moratórios legais possuem natureza jurídica própria, que pode ser diferente daquela do valor principal;
- Não é possível segregar a parcela dos juros qualificável como lucros cessantes daquela que configura danos emergentes.
- A correção monetária embutida na SELIC não constitui um ganho novo, mas a recomposição de uma perda;
- O tratamento contábil dado à devolução dos tributos, com a sua inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não guarda relação com o tratamento a ser dado à Taxa SELIC, devido a sua natureza autônoma em relação à verba principal;
- Essa construção está em consonância com a decisão prolatada por esse Eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.091 (Tema 808).

96. Verifica-se, da análise, que os votos dos Ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, seja de forma mais sucinta ou mais alongada, acompanharam na íntegra as razões de decidir do voto do Exmo. Ministro Dias Toffoli, o qual, quanto ao mérito, foi seguido também pelos demais Ministros da Eg. Corte. Assim, conforme já demonstrado, não apenas a sua conclusão, mas as suas razões de decidir se tornaram vinculantes.

97. É ainda importante destacar que os três Ministros expressamente citaram o entendimento do Plenário quando do julgamento do RE 855.091 (Tema 808 da RG), em que, pelas mesmas razões jurídicas, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: "*Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função*". Na ocasião foi declarada a não recepção, inconstitucionalidade ou interpretação conforme dos seguintes dispositivos:

> "(...) considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão."[47].

98. Portanto, **as razões de decidir comuns aos votos dos Ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso** – acompanhados dos demais - foram, resumidamente, as seguintes:

> (i) o direito aos juros de mora decorre de um ato ilícito cometido pelo devedor, conforme previsto no Código Civil;
>
> (ii) os danos emergentes são intributáveis pelo imposto de renda e pela CSLL, pois visam à recomposição de uma perda efetivamente sofrida pelo credor;
>
> (iii) os lucros cessantes, por sua vez, podem ser tributados, pois são parcela de ganho de capital que o credor auferiria se a obrigação tivesse sido cumprida pelo devedor a tempo e modo;
>
> (iv) o atraso na obrigação de pagar/devolver dinheiro gera o direito ao pagamento de danos emergentes;
>
> (v) é impossível separar a parcela da SELIC que se refere à correção monetária (danos emergentes) da parcela que se refere aos lucros cessantes, de modo que a presunção é de que, a partir do descumprimento de uma

[47] RE 855.091 (Tema 808 da RG), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.04.2021.

obrigação legal/contratual, toda a SELIC deve ser considerada, para fins de tratamento jurídico-tributário, como danos emergentes; e

(vi) os juros e o principal podem possuir naturezas diferentes e definitivamente essa natureza não está relacionada ao tratamento contábil conferido às parcelas.

99. Considerando as razões de decidir do Eg. STF no julgamento do RE 1.063.187 e no RE 855.091 acima sintetizadas, não é possível a realização de *distinguishing* em relação à Selic que recai sobre o levantamento dos depósitos judiciais tributários, uma vez que ambas são a mesma Selic, contemplando a mesma natureza jurídica de danos emergentes, devendo, portanto, receber o mesmo tratamento por parte dessa Eg. Corte.

100. Essa conclusão se impõe não apenas pelo papel estabilizador e uniformizador que os precedentes constitucionais desempenham em nosso sistema jurídico, mas também na medida em que a manutenção do tratamento diferenciado a ambas as situações produziria gravíssima afronta à isonomia, à legalidade tributária e à capacidade contributiva.

II.4. A afronta à isonomia

101. A controvérsia quanto à incidência de IRPJ e de CSLL sobre a Selic na repetição de indébito e no levantamento de depósitos judiciais é **idêntica**. A discussão envolve, inclusive, o controle de constitucionalidade dos mesmos dispositivos legais, e em face das mesmas violações constitucionais, como se constata do quadro abaixo:

	Questão submetida a julgamento	**Objeto**	**Dispositivos constitucionais violados**
Tema 962 da RG	*"Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito."*.	Inconstitucionalidade da interpretação conferida ao art. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88; art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; art. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional.	Art. 153, III; art. 195, I, *c*
Presente ação direta	Inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre	Inconstitucionalidade da interpretação conferida ao	

	a Selic que corrige os depósitos judiciais tributários.	art. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88; art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; art. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional.	Art. 153, III; art. 195, I, *c*; art. 150, I e II; e art. 145, §1º

102. A partir de 01.01.1995, conforme art. 13, da Lei nº 9.065/95[48], os juros de mora e a correção monetária dos tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido dessa data em diante, são calculados por um único índice, a Selic. Do mesmo modo, por expressa disposição legal, os depósitos judiciais de tributos federais também são corrigidos monetariamente e têm seus juros de mora calculados pela Selic (art. 2ª-A, §2º, da Lei nº 9.703/1998[49]).

103. O entendimento de que a natureza jurídica da Selic que incide sobre os valores devolvidos a título de repetição de indébito é diferente da natureza jurídica da Selic incidente sobre os valores recebidos quando do levantamento de depósitos judiciais, com a devida vênia, é anti-isonômica e inconstitucional, premiando o Estado (que receberá parte do valor retornado em tributo) pela exação indevida objeto da garantia.

104. Isso ocorre porque, na repetição de indébito tributário, o contribuinte vê reconhecido seu direito ao ressarcimento ou compensação de tributo indevidamente pago no passado (art. 165, CTN), devendo seu valor ser atualizado para que não ocorra perda do valor da moeda, que comprometa o seu poder aquisitivo ou que gere enriquecimento sem causa do Estado. Essa premissa é tão cara ao legislador tributário que está prevista expressamente no art. 167 do Código Tributário Nacional:

> "Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

[48] Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Produção de efeito (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)

[49] "Art. 2º-A. Aos depósitos efetuados antes de 1o de dezembro de 1998 será aplicada a sistemática prevista nesta Lei de acordo com um cronograma fixado por ato do Ministério da Fazenda, sendo obrigatória a sua transferência à conta única do Tesouro Nacional. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Vide Lei nº 12.099, de 2009, vigência)
(...)
§ 2º Após a transferência à conta única do Tesouro Nacional, os juros dos depósitos referidos no caput serão calculados na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 12.099, de 2009).". (Dispositivo vigente para depósitos de tributos federais efetuados até 15.09.2024, conforme previsto na Lei nº 14.973/2024).

> I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
> II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
> III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
> (...)
> Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, **dos juros de mora** e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.". (Grifos acrescidos).

105. Assim, na hipótese da repetição (seja via restituição ou compensação), resta claro que o ente que exerceu a competência tributária figura como devedor e o contribuinte como credor. O ente tributante possui a obrigação (art. 37, *caput*; art. 150, IV, CRFB; e art. 165, do CTN) de restituir ao contribuinte o tributo pago com base em lei, ato normativo ou interpretação jurídica ilegal ou inconstitucional, de modo que o descumprimento dessa obrigação geraria enriquecimento sem causa (vedado pelo art. 884 e seguintes do Código Civil, e pelos citados dispositivos constitucionais - moralidade administrativa e não-confisco).

106. O mesmo acontece nas hipóteses de depósitos judiciais de tributos federais. Nesses casos, o contribuinte deposita em juízo o valor integral do tributo com o objetivo de suspender a sua exigibilidade, uma vez que a constitucionalidade ou legalidade desse débito está sendo discutida judicialmente.

107. Aqui, poderia surgir a dúvida sobre a natureza do ato de depositar o tributo e do seu levantamento ao final do processo judicial. Há quem afirme ser o depósito uma faculdade do contribuinte, o que o diferenciaria do pagamento do tributo (uma obrigação) e, portanto, o levantamento do depósito seria diferente da repetição de indébito.

108. No entanto, como já abordado, o depósito judicial é feito para suspender a exigibilidade do crédito tributário sob discussão. Somente ao final, caso o Judiciário reconheça a ilegalidade ou inconstitucionalidade do crédito tributário, surgirá o direito ao levantamento. O depósito é, ao mesmo tempo, uma garantia do juízo e o meio mais seguro que o contribuinte dispõe para questionar o pagamento de tributos inconstitucionais ou ilegais. Sem o depósito, o contribuinte deixaria de cumprir sua obrigação de regularidade fiscal.

109. Não à toa, o Código Tributário Nacional atribui os mesmos efeitos à certidão negativa, que faz prova do pagamento do tributo (art. 205), e à certidão positiva com efeitos de negativa, que faz prova da garantia ou suspensão da exigibilidade do tributo (art. 206). Pagamento e depósito são alternativas – mas não faculdades – para que o contribuinte prove sua regularidade fiscal.

110. Além disso, quem diferencia o depósito da repetição de indébito, por entender que o primeiro é uma faculdade, parte da equivocada premissa de que o pagamento de tributos inconstitucionais e ilegais é uma obrigação do contribuinte. Importante ter em mente que o fato ou ato que gera a obrigação de pagamento de tributos tem três planos: existência, validade e eficácia.

111. O fato gerador e o lançamento administrativo, quando praticados, passam a existir para o direito e produzir efeitos como se válidos fossem, inclusive, constituindo óbice para emissão de certidão de regularidade fiscal.

112. No entanto, caso entenda que aquele fato ou ato se fundamentou em ilegalidade ou inconstitucionalidade, o contribuinte não é obrigado a pagar o tributo que se supõe ilegal ou inconstitucional. Assim, para evitar o abominável "solve et repete", o contribuinte deve ajuizar uma ação para discutir a (i)legalidade ou a (in)constitucionalidade daquele fato ou ato administrativo.

113. Conforme amplamente demonstrado, o reconhecimento ao direito à repetição de indébito ocorre apenas por provimento judicial transitado em julgado que reconheça a ilegalidade ou a inconstitucionalidade (invalidade) da cobrança do tributo. Essa decisão judicial atesta, a um só tempo, a invalidade, a nulidade e a ineficácia da cobrança pautada em ilegalidade ou inconstitucionalidade.

114. Desse modo, nem bem o depósito é uma faculdade do contribuinte nem bem o pagamento de tributo ilegal ou inconstitucional é uma obrigação. Tanto o levantamento de depósitos judiciais quanto a repetição de indébito são exercício regular de um direito, que decorre do reconhecimento de uma ilegalidade ou inconstitucionalidade cometida pelo Fisco, de modo a impedir o enriquecimento sem causa do Estado.

115. Reitera-se: apenas o depósito do valor integral do crédito discutido suspende a sua exigibilidade pelo Fisco. Esse é o meio mais ágil para a suspensão da exigibilidade de créditos tributários e o melhor também para o credor, uma vez que, se a ação for julgada

improcedente, o ente da Federação poderá converter o depósito em renda e extinguir o crédito. No entanto, se o pleito do contribuinte for julgado procedente, ele possui, claro, o direito de reaver os valores a título de tributo que foram depositados.

116. Destaca-se que, com base no princípio da legalidade administrativa (art. 37, da Constituição Federal), os entes só podem agir com base na lei e não contrariamente a ela, devendo, assim, abster-se da prática de atos inconstitucionais ou ilegais. A inadimplência do Fisco para com o contribuinte, pelo exercício de uma obrigação negativa (de não praticar ato ilegal ou inconstitucional), gera direito a perdas e danos por aquele que sofre a cobrança indevida (art. 389, do Código Civil) e a privação de parte do patrimônio do credor para depósito judicial e para a comprovação, em juízo, da inconstitucionalidade e ilegalidade da norma tributária, constitui o Fisco em mora em relação a esses valores (art. 394 e 397, do Código Civil).

117. Assim, **tanto na repetição quanto no levantamento do depósito judicial, os valores a que o contribuinte faz jus são valores de tributos que foram indevidamente pagos (repetição) ou que foram indevidamente cobrados pelo Fisco e precisaram ser depositados, tendo, em ambos os casos, ficado igualmente indisponíveis ao contribuinte para a garantia ou quitação de indébito tributário**. A mesma lógica se aplica ao levantamento dos depósitos efetuados com base no art. 9º, I, da Lei nº 6.830/80[50], com a procedência dos embargos à execução fiscal.

118. Ainda quanto aos depósitos judiciais de tributos federais, é importante destacar que, assim que realizados pelos contribuintes, passam a integrar a conta única do Tesouro Nacional, "independente de qualquer formalidade", conforme resta claro no art. 1º, §2º, da Lei nº 9.703/98[51], podendo a União deles dispor.

119. Sob a ótica orçamentária-financeira da União, portanto, o depósito judicial tem os mesmos efeitos de um puro e simples recolhimento de tributo, passando a compor o

[50] Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

[51] Art. 1º. Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade.
(...)
§ 2º Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.

caixa do Tesouro. Ou seja, o levantamento do depósito pelo contribuinte tem, para a União, a mesma consequência financeira da repetição de indébito.

120. E foi exatamente nesse sentido que se manifestou o Professor Ayres Britto, ao justificar a necessidade de aplicação das razões de decidir do Tema 962 da RG ao levantamento dos depósitos judiciais. Veja-se:

> "Com efeito, no Tema 962, o STF enfrentou a questão atinente à tributação da incidência da SELIC, por IRPJ e CSLL, sobre o objeto da repetição de indébito. No Tema 504 do STJ, sai de cena a repetição de indébito e sobe à ribalta a devolução de depósito judicial. Seria o bastante para tornar impertinente todo o encadeamento de razões que levaram o STF a afastar a tributação da SELIC no primeiro caso? Penso decididamente que não, por verificar uma quádrupla identidade entre as hipóteses.".

121. Assim, são quatro os pontos que o Parecerista elencou para fundamentar a necessária aplicação do Tema 962 da RG ao presente caso:

(i) **IDENTIDADE NORMATIVA** - os dois casos possuem a mesma base de *referibilidade normativa*, tanto no plano infraconstitucional, quanto no constitucional, '*pois concernem, no plano infraconstitucional, à interpretação adequada a ser atribuída ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/1988 e ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, e têm por parâmetro de validade constitucional também os mesmos dispositivos: o inciso III do art. 153 e a alínea 'c' do inciso I do art. 195';*

(ii) **IDENTIDADE JURÍDICO-CAUSAL** - o ato ilícito cometido pelas Fazendas Públicas que dá ensejo à repetição e ao depósito e a necessidade de responsabilização em ambos os casos são idênticos: "*se originam de uma cobrança tributária ilícita, indevida, pela qual a Fazenda Pública deve ser igualmente responsabilizada. Uma mesma hipótese de ilicitude e correlata responsabilização, no caso, que é formal e definitivamente atestada por um pronunciamento judicial, de modo que é a mesma conjuntura jurídica que leva os contribuintes a repetirem o valor indevidamente pago a título de tributo e a levantarem o valor depositado judicialmente para acautelar a discussão sobre uma cobrança tributária indevida*";

(iii) **IDENTIDADE ECONÔMICA**: para o contribuinte, os pagamentos realizados equivocadamente ao Fisco e os depósitos judiciais ensejam a mesma consequência, qual seja, a indisponibilidade financeira decorrente de um ato ilícito praticado pela Fazenda; e

(iv) **IDENTIDADE ORÇAMENTÁRIA**: os valores pagos indevidamente ou depositados judicialmente são direcionados ao mesmo destino provisório: "*Num caso e noutro, os valores aportam na Conta Única do Tesouro Nacional, como determina, no caso dos depósitos judiciais, o § 2º do art. 1º da Lei nº 9.703/1998*".

122. Os pontos acima são sintetizados pelo parecerista da seguinte forma:

> "É o quanto basta para que se perceba a relação de *unha e carne, olho e pálpebra* entre o Tema 962/STF e o Tema 504/STJ, de modo que o desfecho daquele seja reproduzido neste. **Indisponibilidade financeira** causada por um ato ilícito; sua caracterização como dano emergente (e não lucros cessantes); **natureza indenizatória dos juros de mora**; a **autonomia deste em relação à natureza jurídica da verba em atraso**, inclusive quanto ao tratamento contábil; a **impossibilidade de se fracionar o conteúdo econômico da SELIC**; a **consonância com a decisão tomada no Tema 808 de Repercussão Geral**, no sentido já aqui registrado de que 'não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função'**: todos, rigorosamente todos os elementos constitutivos das razões decisórias do Tema 962/STF se amoldam à controvérsia instaurada no Tema 504/STJ**."

123. Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Professor Paulo Ayres Barreto, da Faculdade de Direito da USP, ao afirmar que:

- A natureza da SELIC que incide sobre a repetição e sobre o levantamento de depósitos é de danos emergentes. Classificá-la como lucros cessantes significa presumir que o contribuinte aplicaria os valores "*em investimentos diversos, com remunerações distintas*", no entanto, tal conclusão não é plausível, uma vez que o contribuinte poderia usar os valores "*para o pagamento de custos e despesas relacionados à própria atividade da empresa*, o que é mais *consentâneo com a realidade da maior parte das empresas do País*";

- Tanto na repetição quanto no levantamento de depósitos, os numerários só serão devolvidos aos contribuintes "*se houver decisão definitiva do Poder Judiciário no sentido de que* ***a exigência fiscal nunca fora devida, de modo que a União deu causa, indevidamente, à privação do patrimônio do contribuinte.***";

- "*Por isso, em ambos os casos, incide a Selic, por determinação legal, para indenizar o contribuinte dos danos ocasionados pelo ilícito que o levou a ficar privado dos seus recursos durante o trâmite do processo judicial. Nem em um caso nem no outro há qualquer relação do valor acrescido ao montante nominal devolvido com o que o contribuinte deixou de ganhar (lucros cessantes), como bem analisou o STF no julgamento do Tema 962.*";

- "*O depósito é efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, inexistindo escolha sobre a taxa, o prazo ou o credor. Trata-se de medida que visa à concretização e execução do direito de defesa (CF/88, art. 5º, LV)*";

- "*A adoção do entendimento no sentido de que haveria a tributação da Selic incidente sobre depósitos judiciais implicaria desincentivo dessa modalidade de garantia em prol de outras (seguro-garantia, fiança bancária, etc.) que não proporcionam à União disponibilidade imediata sobre os recursos, acabando por mais prejudicar as contas públicas do que ajuda-las.*"; e

- "(...) *a forma de contabilização da Taxa Selic incidente sobre a repetição do indébito tributário e os depósitos judiciais, sejam eles referentes a tributos dedutíveis em relação à base de cálculo do IRPJ e da CSLL ou não, é*

> *absolutamente irrelevante para a não incidência dos tributos sobre receita em relação a estas parcelas, por tratar-se de indenizações por danos emergentes*", conforme chancelado pelo STF quando da análise do Tema 962 da RG.

124. Desse modo, com a devida vênia, não há espaço para qualquer *distinguishing*, uma vez que o Tema 962 da RG e a presente ação versam exatamente sobre os mesmos fatos relevantes: a inconstitucionalidade de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige valores que serão devolvidos ao contribuinte por inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato do ente tributante, reconhecida judicialmente.

125. A manutenção de tratamentos díspares a situações equivalentes, além de ferir a racionalidade jurisdicional almejada pelo sistema de precedentes, fere frontalmente o princípio geral da igualdade (art. 5º, *caput*, da Constituição Federal) e o seu desdobramento em matéria tributária, o princípio da isonomia (art. 150, II, da Constituição).

126. Sobre a relação da igualdade com o sistema de precedentes constitucionais, verifica-se que:

> "O princípio geral da igualdade pode se relacionar com o sistema de precedentes de três formas: (i) como mandamento de vedação à criação de discriminações injustificadas pelo Estado (em que se inclui o Judiciário); (ii) ao restringir a possibilidade de que o Judiciário confira soluções diversas a problemas equivalentes, naquilo que Marinoni chamou de *igualdade perante a interpretação da lei;* e, assim, (iii) impor vedação ao tratamento parcial por parte do julgador, perfazendo verdadeira garantia de parcialidade.
>
> Observa-se que, em relação ao primeiro ponto, trata-se de aplicação 'endógena' da igualdade pelo juiz, que no âmbito da própria decisão, não pode produzir norma que a contrarie. Em relação ao segundo ponto, a igualdade perante a interpretação da lei consubstancia a ideia de que a(s) norma(s) criada(s) pelo Judiciário para a solução de casos concretos devem ser universalizáveis, conforme defendido por MacCormick. Assim, as razões de decidir extraídas de um julgado devem ser aplicadas a todos os casos que a elas se subsumirem pelo dever de isonomia que vincula a atuação do juiz em um sistema de precedentes. Trata-se da aplicação 'exógena' da igualdade, referente à aplicação de uma decisão a casos análogos ao precedente."[52].

127. Por uma singela, porém relevante peculiaridade do princípio da isonomia tributária, transcrevemos o respectivo dispositivo constitucional:

> "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
> (...).

[52] PENCAK, Nina Pinheiro. *Direito tributário e controle de constitucionalidade:* o STF como intérprete da Constituição tributária à luz do sistema de precedentes. 2025. 491f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025, p. 269.

> II - instituir tratamento desigual entre **contribuintes que se encontrem em situação equivalente**, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; (...)" (Grifos acrescidos).

128. Sobre a isonomia tributária, "*Destaca-se que o próprio texto constitucional reconheceu, ao menos em matéria tributária, que a igualdade de tratamento entre contribuintes não se limita àqueles que se encontrem em situação idêntica, mas em situações que sejam valoradas da mesma forma, que equivalham 'em termos quantitativos, apesar de apresentar[em]-se sob forma diferente'. Em outras palavras, depreende-se que o constituinte entendeu que as normas tributárias não podem discriminar contribuintes, desde que eles estejam em situação que seja considerada equivalente.*"[53].

129. É inegável, portanto, a equivalência entre a repetição de indébito e o levantamento de depósitos judiciais que atrai a necessidade de tratamento isonômico à Selic que corrige ambas.

130. Essa equivalência já foi, inclusive, reconhecida pela própria União que, para fins orçamentários equiparou ambas as situações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, quando afirma que:

> "De acordo com a Lei nº 9.703, de 13 de novembro de 1998, os depósitos judiciais são efetuados em conta corrente da Caixa Econômica Federal (CAIXA) e seus recursos repassados à Conta Única do Tesouro Nacional. Em a decisão da lide sendo favorável ao contribuinte, a devolução do depósito deve ser feita em até vinte quatro horas. **O levantamento de depósito possui natureza semelhante à restituição de tributos**. Em a decisão sendo contrária ao contribuinte, há a conversão do depósito em renda transformando-se, assim, em pagamento definitivo".

131. Assim, considerando que a Selic incidente na repetição de indébito e no levantamento de depósitos judiciais possui a mesma natureza, incabível eventual distinção em relação às razões de decidir firmadas no RE 1.063.187 (Tema 962 da RG) e a situação apresentada nesta ADI. A tributação da Selic pelo IRPJ e pela CSLL fere, em ambas as hipóteses, a interpretação conferida ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); e ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92, que excluiu, inequivocamente, do conceito de *"acréscimos patrimoniais"*, os danos emergentes representados pelo referido índice.

[53] Op. Cit. p. 271.

132. Assevera-se que o respeito aos precedentes é o principal meio que o Judiciário - e sobretudo os Tribunais Superiores –, dispõem para resguardar a segurança jurídica e a isonomia, e implementar o princípio democrático, via colegialidade (art. 926, do CPC/2015).

133. A criação de discriminações no âmbito das normas produzidas pelo Eg. Supremo Tribunal Federal por meio de seus precedentes vinculantes gera estímulos e desestímulos indesejados e imponderados pela própria Eg. Corte, conforme apontou o Professor Paulo Ayres Barreto:

> "O depósito é efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, inexistindo escolha sobre a taxa, o prazo ou o credor. Trata-se de medida que visa à concretização e execução do direito de defesa (CF/88, art. 5º, LV). (...).
>
> A adoção do entendimento no sentido de que haveria a tributação da Selic incidente sobre depósitos judiciais implicaria desincentivo dessa modalidade de garantia em prol de outras (seguro-garantia, fiança bancária, etc.) que não proporcionam à União disponibilidade imediata sobre os recursos, acabando por mais prejudicar as contas públicas do que ajuda-las.".

134. É imperioso, portanto, sob pena de perpetuação da afronta à isonomia, que sejam aplicadas, ao presente caso, as já citadas razões de decidir que levaram à declaração de inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic no RE 1.063.187 (do Tema 962) pelo Eg. STF.

II.5. A afronta à legalidade tributária

135. O art. 150, I, da Constituição Federal, impõe que apenas por lei em sentido estrito um ente pode exigir ou aumentar tributo. Essa é a leitura tradicional do referido dispositivo.

136. No entanto, dele também extraímos a impossibilidade da escolha arbitrária da abrangência das razões de decidir de um precedente, de modo que essa escolha resulte em situação de incidência tributária prevista em lei ou em interpretação de lei já declarada inconstitucional[54].

[54] Esse argumento foi originalmente sustentado em: PENCAK, Nina Pinheiro. *Direito tributário e controle de constitucionalidade:* o STF como intérprete da Constituição tributária à luz do sistema de precedentes. 2025. 491f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025, p. 285 e seguintes.

137. Desse modo, considerando que esse Eg. Tribunal, quando do julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962 da RG), conferiu interpretação conforme à Constituição ao §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), "*de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário*", é forçoso que se reconheça que, desde então, não existe suporte legal válido a fundamentar a exigência dos tributos federais que incidem sobre a Selic em situações equivalentes (como o é o levantamento dos depósitos judiciais tributários)[55].

138. Não se trata aqui da antiga distinção entre texto e norma, mas da impossibilidade de se criar *distinguishing*s randômicos, não apenas porque afrontam ao princípio da isonomia, mas porque, no presente caso, violaria a legalidade tributária, uma vez que já foi decidido em precedente vinculante que a Selic configura danos emergentes e, portanto, não está no âmbito de incidência das referidas normas.

139. Como a Selic que corrige a repetição é a mesma que corrige o levantamento dos depósitos judiciais realizados até 15.09.2024, permitir a tributação da segunda é permitir a incidência de IRPJ e de CSLL com base em dispositivos de leis já declarados inconstitucionais, o que desrespeita de forma manifesta a legalidade tributária.

II.6. A afronta à capacidade contributiva e ao não confisco

140. Não bastasse todo o exposto, a incidência de IRPJ e CSLL sobre as parcelas correspondentes a juros e correção monetária viola, ainda, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não-confisco.

141. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública tem o dever de agir com razoabilidade e proporcionalidade, atuando por meio de práticas eficazes que assegurem a finalidade almejada, qual seja, resguardar o interesse público.

142. No presente caso, não há que se falar em interesse público a ser resguardado ante a tributação de grandezas que não denotam riqueza sujeita à tributação para

[55] Op. Cit.

manutenção das atividades estatais. Ao contrário, juros e correção monetária correspondem à indenização ao contribuinte e à recomposição de seu patrimônio.

143. A capacidade contributiva, por sua vez, é prevista no artigo 145, §1º, da Constituição, como desdobramento da isonomia (artigo 150, inciso II), que impõe a existência de uma dimensão econômica (pecuniária) intrínseca ao fato sobre o qual recai o tributo.

144. Para além de elemento identificador da renda, a capacidade contributiva é verdadeiro **pressuposto** de exercício da competência tributária, que necessariamente deverá eleger como base de cálculo os fatos que exprimam riqueza. A atualização dos depósitos judiciais de débito tributário não denota riqueza passível de tributação – o chamado *"signo presuntivo de riqueza"*. Nesse sentido, Ricardo Lodi Ribeiro, Professor de Direito Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro:

> "Em seu primeiro aspecto objetivo, a Capacidade Contributiva constitui fundamento constitucional para a exigência tributária, **uma vez que não há tributação onde não há manifestação de riqueza**. Ademais, o plano objetivo se completa pelo segundo aspecto, revelado na diretriz constitucionalmente firmada para a **eleição pelo legislador de um fato gerador que seja revestido de conteúdo econômico. Tal dimensão objetiva será, portanto, violada quando houver tributação de atos que não se revelem em signos presuntivos de riqueza** (...)."[56] (Negritos acrescidos).

145. Ausente o elemento de expressão de capacidade contributiva nos juros indenizatórios e na correção monetária, conforme reconhecido no RE 1.063.187 (Tema 962 da RG), sua tributação pelo IRPJ e pela CSLL ofende o princípio protegido pelo artigo 145, §1º, da Constituição Federal.

146. A exigência ora impugnada viola também o artigo 150, inciso IV, da Constituição, que limita expressamente o poder do Estado para a instituição e cobrança de tributos: *"Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios* ***utilizar tributo com efeito de confisco"***.

147. A tributação ora questionada viola o **princípio do não confisco,** pois representa exigência, por parte do ente público, de valores que acarretam a *absorção total ou parcial da propriedade privada, sem indenização*[57]. Isso porque, se há tributação além da

[56] RIBEIRO, Ricardo Lodi. *Limitações constitucionais ao poder de tributar*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 155.
[57] BARRETO, Aires F. *ISS na Constituição e na lei*, São Paulo: Dialética, 2003, p. 17.

capacidade contributiva, o Estado não tributa a renda ou lucro, mas, sim, patrimônio do contribuinte.

148. Também por essas razões, deve ser afastada a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente à Selic que corrige os depósitos judiciais relativos à débitos tributários.

II.7. Subsidiariamente: a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a parcela de correção monetária que compõe a Selic

149. Conforme exposto, a Selic é composta de parcela referente à correção monetária e parcela referente a juros moratórios indenizatórios, que essa Eg. Corte já entendeu possuir a natureza jurídica de **danos emergentes**, quando do julgamento do Tema 962 da RG, motivo pelo qual não configura acréscimo patrimonial passível de ser tributado por IRPJ e por CSLL.

150. Nesse sentido, destaca-se que o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso explicou em seu voto, no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), em consonância com o sustentado pelo Exmo. Min. Dias Tofolli, que:

> "15. **A taxa SELIC possui uma natureza dúplice**, já que, por um lado, procura refletir a expectativa de rendimento do capital, tendo por base os empréstimos bancários em um mercado com lastro em títulos públicos federais negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia; e, por outro lado, considera a instabilidade do poder de compra da moeda, atuando como um mecanismo de neutralização dos efeitos inflacionários.
>
> 16. Veja-se que essa afirmação não significa que a taxa SELIC efetivamente contém a correção monetária no seu resultado, no sentido de sempre, ao menos, equivaler à inflação do período. Pode haver taxa SELIC superior à inflação (juros reais positivos) ou inferior a esta (juros reais negativos)[58]."

151. No entanto, como visto, a Primeira Seção do Eg. STJ, quando da reanálise da tese que havia firmado nos Temas Repetitivos 504 e 505, entendeu que apenas a Selic que corrige a repetição de indébito possuiria natureza de danos emergentes, enquanto a Selic

[58] STF, RE 1.063.187, Tribunal Pleno, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe-247, 16 dez. 2021.

que corrige o levantamento de depósitos judiciais teria natureza de lucros cessantes, uma vez que os juros moratórios seriam remuneratórios e não indenizatórios.

152. Mesmo admitindo a **impossibilidade de tributação da correção monetária**, aquela Eg. Corte de Justiça decidiu que **toda a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais é lucros cessantes**, e, portanto, acréscimo patrimonial, inclusive a parte que se refere à correção monetária.

153. Desse modo, caso essa Eg. Corte decida por manter as premissas adotadas pelo Eg. STJ, no sentido de que apenas a parte dos juros da Selic que recai sobre os depósitos deveria ser tributada por configurar lucros cessantes, é necessário que se adeque, ao menos, a conclusão a que chegou aquele Tribunal. Portanto, na atualização de depósitos judiciais, deve ser excluída da tributação por IRPJ e por CSLL a parcela da Selic correspondente à correção monetária.

154. Assim, subsidiariamente, a Requerente pleiteia que, na hipótese de se entender pela possibilidade de tributação por IRPJ e CSLL da parte referente aos juros de mora que compõem a Selic que corrige os depósitos, que essa Eg. Corte, com base nos seus precedentes, declare a inconstitucionalidade da incidência dos tributos federais sobre a parcela referente à correção monetária.

I. OS PEDIDOS

III.1. O pedido cautelar

155. Conforme art. 102, I, *p*, da Constituição Federal, e art. 10 e seguintes, da Lei nº 9.868/99, é possível que essa Eg. Corte conceda a medida cautelar pleiteada pelo Requerente desde que observado o cumprimento de dois requisitos – *fumus boni iuris* e *periculum in mora* – ambos presentes no caso concreto.

156. Quanto ao *fumus boni iuris,* o direito suscitado pela Requerente é mais do que plausível e foi exaustivamente demonstrado ao longo da presente petição. Conforme decidido por essa Eg. Corte no RE 1.063.187 (Tema 962 da RG) a Selic aqui discutida possui natureza de danos emergentes, não configurando renda, lucro ou qualquer acréscimo

patrimonial. As razões de decidir desse precedente qualificado, em que pese vinculante a todo o Judiciário e ao Poder Executivo (art. 102, §3º, da Constituição e Tema 885 da RG), não têm sido aplicadas à situação equivalente objeto desta ADI, de modo que a Selic que corrige os depósitos judiciais efetuados até 15.09.2024, continuam a sofrer a incidência de IRPJ e de CSLL.

157. Tal situação, além de representar uma gravíssima ofensa ao Tema 962 da RG e ao Tema 808 (ou, no mínimo, às suas razões), conforme exposto, viola *per se* os conceitos constitucionais limitadores da competência tributária da União previstos no art. 146, III, *a*; 153, III; e 195, I, *c*, da Constituição Federal.

158. Ao perpetuar a cobrança de IRPJ e CSLL sobre a Selic no levantamento de depósitos judiciais tributários, a União cria, com a chancela do Eg. Superior Tribunal de Justiça, situação verdadeiramente anti-isonômica, discriminando contribuintes que se encontram em situações equivalentes – aqueles que pagaram e pediram repetição e aqueles que depositaram -, em contrariedade ao art. 5º, e art. 150, II, da Constituição. É clara, ainda, a afronta à legalidade tributária, à capacidade contributiva e ao não-confisco, posto que se tributa fato que não consubstancia signo presuntivo de riqueza, pois possui reconhecida natureza indenizatória.

159. Igualmente presente está o requisito do *periculum in mora*. Isso porque o precedente do Tema 962 firmado em 2021, e integrado por v. acórdão de embargos de declaração em 2022, está em vigor há quase quatro anos, sem ser devidamente observado pela União e pelo Poder Judiciário federal, no que se refere às suas razões de decidir.

160. Desse modo – e sobretudo após a negativa, pela Primeira Seção do Eg. STJ, da readequação da tese firmada no REsp nº 1.138.695 (cujos embargos de declaração foram julgados em 06.02.2025) – o entendimento da União no sentido da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais ganhou ainda mais força, fomentando a judicialização da matéria e o temerário cenário de justiça lotérica.

161. Há de se observar, ainda, que o risco em discussão é contemporâneo e se concretiza a cada dia, uma vez que, conforme se dão as liberações do levantamento dos depósitos judiciais tributários, o Fisco federal procede às consequentes autuações – gerando a necessidade de novos depósitos para discussão do novo suposto débito, em verdadeiro ciclo de insegurança e onerosidade ao contribuinte.

162. Faz-se, pois, imperioso que essa Eg. Corte, liminarmente, decida pela suspensão da eficácia da interpretação conferida ao art. § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); e ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92; 57 da Lei nº 8.981/1995, de modo a excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento dos depósitos judiciais, até o julgamento de mérito da presente ação.

163. Subsidiariamente, requer-se que essa Eg. Corte suspenda nacionalmente a tramitação de ações de judiciais e processos administrativos que versem sobre a matéria, para evitar que ocorra o trânsito em julgado e o perecimento do direito dos contribuintes. Faz-se, necessário, ainda nessa hipótese, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IRPJ e CSLL para que se evite que os contribuintes ingressem em juízo para discutir as cobranças, o que gerará uma enorme quantidade de litígios.

164. Por fim, não há que se falar em *periculum in mora reverso*, na medida em que a União, na hipótese de se sagrar vencedora, poderá dar continuidade às cobranças administrativas e judiciais dos referidos tributos, não havendo que se falar em perecimento do seu suposto direito.

III.2. Requerimentos, pedidos principais e pedidos subsidiários

165. Por todo o exposto, a CNSaúde requer:

(i) **preliminarmente,** o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade posto restarem cumpridos os requisitos constitucionais (art. 102, I, *a*, e 103, IX, da Constituição Federal) e legais (art. 2º e seguinte da Lei nº 9.868/99);

(ii) **ainda preliminarmente**, e em caráter subsidiário, caso essa Eg. Corte entenda que o art. 37, II, da Lei nº 14.973/2024 – que, frise-se não é objeto da presente ação - teria alterado o cenário fático-jurídico de correção dos depósitos judiciais federais, em nome do princípio da fungibilidade e restado cumprido o requisito da subsidiariedade, que a presente ADI seja recebida como arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos dos precedentes dessa Eg. Corte (p. ex. MC ADI 4.180, Rel. Min. Cezar Peluso);

(iii) **liminarmente, nos termos do art. 102, I, *p*, da Constituição Federal,** a concessão da cautelar acima pleiteada *inaudita altera parte* e *ad referendum* do Plenário, conforme previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/99, a fim de suspender a eficácia da interpretação conferida ao art. § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); e ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92; 57 da Lei nº 8.981/1995, de modo a excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento dos depósitos judiciais, até o julgamento de mérito da presente ação. **Subsidiariamente**, requer-se que essa Eg. Corte suspenda nacionalmente a tramitação de ações de judiciais e processos administrativos que versem sobre a matéria, para evitar que ocorra o trânsito em julgado e o perecimento do direito dos contribuintes. Faz-se necessário nessa hipótese o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IRPJ e CSLL já lançados para que se evite que os contribuintes ingressem em juízo para discutir as cobranças, o que gerará uma enorme quantidade de litígios;

(iv) **sucessivamente**, *(a)* a notificação das autoridades competentes pela edição dos atos normativos impugnados para prestar informações no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º, *caput* e parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e, na sequência *(b)* a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, conforme art. 8º da Lei 9.868/99;

(v) **no mérito**, a confirmação da medida liminar para que se confira interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); e ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92; 57 da Lei nº 8.981/1995, a fim de declarar sua **inconstitucionalidade parcial sem redução de texto**, de modo a **excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento dos depósitos judiciais**; e

(vi) **subsidiariamente**, **no mérito**, que se confira interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); e ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92; 57 da Lei nº 8.981/1995, de modo a excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência de IRPJ e CSLL sobre a parcela da Selic que equivale apenas à correção monetária (inflação) e que recai sobre o levantamento dos depósitos judiciais pelos mesmos fundamentos expostos.

166. Por fim, requer que todas as futuras publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado **BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS**, inscrito na OAB/SP nº 224.120, com endereço profissional na Avenida Paulista, número 1776, 23º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310-200; e do escritório **MUDROVITSCH ADVOGADOS**, registrado na OAB/DF nº 2037/12, com sede na SHIS, QI 3, Conjunto 6, Casa 25, Brasília/DF, CEP 71605-260.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 02 de maio de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Breno Ferreira Martins Vasconcelos
OAB/SP 224.120

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch
OAB/DF 26.966

Nina Pinheiro Pencak
OAB/RJ 186.829

Victor Santos Rufino
OAB/DF 57.089